

MANUAL DE DERECHO ROMANO

Di Pietro

DER. CONSUE.

JURISPRUDENCIA

JURISDICCION

LEGISLACION

SISTEMAS

MORES
MAIORUMINTERPRETACION
Y
JURISDICCION (27)

PONTIFICIAL

Ius flavianum
JURISPRUDENCIA

LAICA

IUS PUB.
RESPONDENDI
ESCUELASTEORIA
DE LA
CONSUETUDO
Y DE LA
DESUETUDO

Ley de citas

LEGIS
ACTIONS

Pretor

Pretor
peregrino

Lex Aebutia

PROE.D.
FORMULARIOP.O.C.
EXTRAORDINARIO
Edicto
perpetuo

FEDERA

Lex XII T. (27)

LEGES

ROGATAE

CONSTITUCIONES

IMPERIALE
Comp.S
de JustinianoLEGES
REGIAE

PLEBISCITOS

CONSULTOS

Código
Teodos.Leyes
romano-
bárbaras

IUS

CIVILE

IUS
GENTIUMIUS
NOVUM

IUS

QUIRITIMUM

IUS

CIVILE

IUS
NOVUMIUS
NOVUM

IUS

NOVUM

IUS

NOVUM

IUS

LEGITIMUM

IUS

HONORARIUM

IUS
NOVUM

IUS

NOVUM

IUS

NOVUM

— 700 —

— 650 — Septimontium

— 600 — Unión latino-sabina

— 550 — Predominio etrusco

— 500 — Caída de la monarquía

— 450 — Patricios y plebeyos

— 400 —

Comienzo de la res pública

Lex Poetilia Papiria

— 250 — Control romano sobre toda la península

— 200 — 2ª Guerra Púnica
Influencias helénicas

— 150 — Destrucción de Cartago y Corinto

— 100 — Gracos
Guerra social y extens. de la ciudadanía a la península.Guerras civiles
Iniciación del Principado
Siglo de Augusto

50 — Dinastía Flavia

— 100 — Dinastía de los Antoninos

— 150 — Dinastía de los Severos
Constitución de Caracalla

— 200 — Anarquía militar

— 250 — Iniciación del Dominado
Edicto de Milán

— 300 — Cristianismo, religión del Imperio dividido definitivamente

— 350 —

— 400 — Fin del Imperio de Occidente

— 450 — Lex Romana visigotorum

— 500 — Muerte de Justiniano

Blondi	Hugo	Guarino	Ricco-bono	Bon-fante	Perozzi
A	I	A	N	Q	
R	N	A	A	U	
C	F	R	C		
A	A	C			
I	N				
C	C				
O	I				
	A				
R		C			
E	J	O			
P	U				
U	V	P			
B	E	R			
L	N	E			
I	T	C			
C		L			
A		A			
N	D	S.			
O					
	V				
C	I	C			
L	R	L			
A	I	A			
S	L	S			
I	I				
C	D	C			
O		O			
P	V	P			
O	E	O			
S	J	S			
T	E	T			
C	Z	C			
L		L			
A		A			
J					
U					

ROMANO
HELENIC

34(37)

DIP

01125

ADVERTENCIA

os de concisión y desarrollo esquemático han llevado a una
enci6n del aparato crítico y la cita bibliográfica.

iones exigidas por la compleja interrelación de los temas y
su ordenamiento han sido resueltos con la inserción de un asterisco al
lado de la palabra que se invita al lector a buscar en el índice analítico,
para ubicar allí el lugar o lugares donde el concepto en cuestión se
encuentra definido, aludido o desarrollado con más amplitud.

CAPITULO I

NOCIONES PRELIMINARES

CONCEPTO DE DERECHO ROMANO

Es el complejo de ideas, experiencias y ordenamientos jurí-
dicos que sucedieron a lo largo de la historia de Roma, abar-
cando desde los orígenes de la ciudad estado hasta la disgrega-
ción de la parte occidental del Imperio o, mejor, hasta la muerte
de Justiniano (565 d.C.).

- * Bajo la denominación de Derecho Romano se significaron diferentes
cosas a lo largo de los siglos. Así, para el estudioso medieval del siglo
xiii, Derecho Romano era la compilación justiniana, la que en 1583
fue designada por el jurista Dionisio Godofredo *Corpus iuris civilis* (sistema del derecho civil).
- * Con posterioridad al siglo xiv se consideró Derecho Romano a la elabo-
ración doctrinaria producto de la adaptación del *Corpus iuris* a las
necesidades de la sociedad europea en rápido desarrollo económico y
social.
- * Después de entenderse como Derecho Romano a este derecho común
europeo y cuando ya se estaban perfilando los sistemas jurídicos nacio-
nales se designó Derecho Romano actual o Pandectística a la armoni-
zación teórico-práctica que hicieron los juristas alemanes en el siglo
xix, y que fue fuente de derecho positivo en Alemania hasta la pro-
mulgación del Código Civil alemán de 1900.

El Derecho Romano tuvo, pues, dos vidas: la primera, ubi-
cada en la época histórica romana, como un proceso concreto y
natural de vivencias, valoraciones y normas; la segunda, como
un complejo de normas que, de una manera u otra, tuvo vigencia
en el occidente europeo hasta los umbrales del siglo xx, no por
imposición de un poder estatal sino por la generalizada concien-
cia de su valor técnico y de la justicia o equidad de sus soluciones.

- 1ª edición: 1982.
- 1ª reimpr.: 1983.
- 4ª edición: 1985.
- 1ª reimpr.: 1991.
- 2ª reimpr.: 1992.
- 3ª reimpr.: 1994.
- 4ª reimpr.: 1994.
- 5ª reimpr.: 1995.
- 6ª reimpr.: 1996.
- 7ª reimpr.: 1999.

I.S.B.N. 950-14-0286-X (4ª ed.)

EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

LEXIS-NEXIS ARGENTINA S.A.

Takcaluano 494 (C1013AAJ)

Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 5382.8806 - <http://www.depalma.com.ar>

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Derechos reservados.

Impreso en la Argentina. Printed in Argentina.

Es decir que se impuso no *ratione imperii* (en razón del poder), sino *imperio rationis* (por el poder de la razón).

NOCIONES FUNDAMENTALES

IUS

Es el equivalente latino de nuestro vocablo derecho. Puede aparecer también, según su función sintáctica, bajo las formas *iure* (de acuerdo a derecho), *iuris* (de derecho), *iuri* (para el derecho).

I. En primer lugar, *ius* significa el conjunto de normas que constituyen un ordenamiento jurídico. En otros términos, *ius* es el derecho objetivo.

- *Ius* designa un derecho positivo. Para referirse al derecho como valor ideal, los romanos usaban las expresiones *aequitas* o *aequum et bonum* o calificaban a *ius* como *naturale*.
- Los romanos no definieron abstractamente al *ius* como ordenamiento jurídico. La definición de Celso "*ius est ars boni et aequi*" ("el derecho es la ciencia de lo conveniente y de lo justo") se refiere, en realidad, a la actividad o disciplina de los juristas, que debe así anciliar, de una manera realista, lo que resulta justo y adecuado a las necesidades sociales del momento.
- Sería incorrecto traducir *bonum* como "lo bueno moral" y así achacarle a Celso el confundir lo jurídico y lo moral. Por otra parte, si bien el ordenamiento jurídico no prescribía una conducta moral, la tenía constantemente en cuenta, como lo prueban la vigilancia ejercida por el censor, la anulación de obligaciones cuyos objetos resultaran inmorales y la amplitud dada a la *exceptio doli*.

II. Actualmente es controvertido si la acepción de *ius* correspondería plenamente a la nuestra de derecho subjetivo, especialmente si tomamos en cuenta que los juristas romanos no determinaban si en un caso dado una persona tenía un derecho subjetivo, sino si le era otorgada o no una acción. Así, el pretor no concedía o negaba derechos sino acciones; su edicto era un repertorio de acciones para las distintas situaciones que se podían presentar.

III. *Ius* significa también status, condición o situación jurídica.

dica; por ejemplo, *sui iuris* se decía de una persona dotada de capacidad de derecho.

IV. Otro significado de *ius* sería el de expresión ritual. Esto por el pensamiento mágico religioso que atribuía a ciertas palabras o gestos un poder creador de derecho: "*Ius feci*" significaría "he cumplido el rito".

V. *Ius*, además, designa el encuadre jurídico de una situación o cosa. Así, *iuris dictio* (expresión del derecho) es la facultad del magistrado de plantear o imposter jurídicamente una controversia.

VI. Por último, *ius* se usaba para designar la etapa procesal que estaba a cargo del magistrado y, por extensión, el ámbito físico del tribunal.

IUS PUBLICUM-IUS PRIVATUM

IUS PUBLICUM

Tuvo dos acepciones: una hacía referencia a la fuente de las normas y la otra a su ámbito de regulación.

(A) Teniendo en cuenta la fuente, *ius publicum* es el derecho creado por el estado —*lex publica*, senadoconsulto, constitución imperial, etcétera—. En la época republicana se usó como sinónimo *ius legitimum*.

(B) Por el objeto, *ius publicum*, según Ulpiano, es el que atañe al modo de ser (*status*) de la organización del pueblo romano.

- No coinciden las normas que comprenden una y otra acepción: las que regulan la estructura y el ordenamiento del estado tienen su origen en la praxis consuetudinaria y no necesariamente en las leyes públicas, que, en cambio, devinieron la fuente paulatinamente preponderante en materia de relaciones entre particulares, es decir, de derecho privado.

IUS PRIVATUM

Ulpiano lo define como el referente al interés de los particulares y como tripartito: consta del *ius civile*, del *ius gentium* y del *ius naturale*.

5-041 2

Ius civile. — Abarca en principio la totalidad del ordenamiento romano exclusivamente de y para los ciudadanos romanos, dado el principio de personalidad * de las leyes.

Ius gentium. — Teóricamente, según una definición pedagógica de Gayo, es el derecho que, resultando de la intelección o captación de un orden natural en la realidad, tiene aplicación en todos los pueblos. *Ius gentium*, en cambio, como concreta realización histórica, es el conjunto de normas e instituciones de derecho positivo, producto de la actividad del pretor peregrino para ser aplicado a las relaciones entre ciudadanos romanos y peregrinos * o entre éstos.

Ius naturale. — Parece haber resultado de un desglose de la ya mencionada concepción de Gayo del *ius gentium*. Este autor solía, por lo demás, utilizar la expresión *ius naturale* para acentuar el carácter racional de algunas instituciones del *ius gentium*. Posteriormente, la doctrina dio diferentes definiciones del *ius naturale*. Para Paulo es "lo que siempre es justo y conveniente". Para Ulpiano, lo que la naturaleza ha inculcado a todos los seres animados "...como la unión del macho y de la hembra, la procreación y educación de los hijos". Por último, en las "Instituciones" de Justiniano encontramos una definición en la que se puede ver una fuerte influencia del cristianismo: "El derecho natural, que en todos los pueblos se observa por igual, establecido por una cierta providencia divina, permanece fijo e inalterable".

FAS

Ius debía coexistir originariamente, en las concepciones del romano primitivo, con *fas*, vocablo probablemente vinculado con *fari* (hablar, manifestarse); el concepto contrario, *nefas* (de donde proviene nefasto), equivale a tabú, lo prohibido por el mundo mágico religioso. Con el correr del tiempo y la laicización del derecho, *fas* persistió significando el ámbito de lo permitido por manifestación de la divinidad, a diferencia de *ius*, que adquirió el valor de ordenamiento jurídico humano.

IUSTITIA

Según Ulpiano, "justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo". La caracteriza como una virtud y no como una abstracción de "todo lo conforme a derecho" como podría esperarse de su derivación de *iustus* (de acuerdo al *ius*).

IURISPRUDENTIA

De *iuris* (de derecho) y *prudencia* (sabiduría, experiencia previsto a). La definición de Ulpiano, "el anoticiamiento de las cosas divinas y humanas y la sabiduría discernidora de lo justo y de lo injusto", nos recalca el carácter realista y plástico —ajeno a esquemas utópicos y atento a las necesidades y aspiraciones de la vida comunitaria— que tenía la jurisprudencia romana.

AEQUITAS

Tuvo dos significados. En las épocas preclásica y clásica equivalía a justicia, valor ideal al que tiende y con el que se justifica la norma. En la época justiniana, el otro sentido del vocablo —impregnado de concepciones cristianas tales como la caridad, benevolencia y benignidad— aparece como un criterio extrajurídico, al margen y contrapuesto a la rígida norma positiva.

CARACTERES DEL DERECHO ROMANO

De los diversos aspectos que destacaron al Derecho Romano entre los otros derechos de la antigüedad y que, de una forma u otra, aseguraron su permanencia, podemos citar los siguientes.

(A) Prudente armonización de la libertad con el principio de autoridad. — La plena regulación de la vida social permite el juego autónomo de la libertad individual.

(B) Continuidad en la evolución jurídica. — Como resultado de una combinación de reverente tradicionalismo y de apertura a los nuevos requerimientos sociales. Las instituciones que comienzan a ser obsoletas no se destruyen sino que se las mantiene al lado de las que van surgiendo. Esto lleva a un acumularse de experiencias y resultados, a la convivencia y estratificación de fuentes y sistemas de derecho.

(C) Pluralidad de fuentes y sistemas jurídicos. — Coexistencia de estructuras jurídicas distintas y contrapuestas entre sí, en su campo de aplicación, origen o fundamento: un *ius civile* —derecho exclusivo de los ciudadanos romanos— contrapuesto a un *ius gentium* —derecho para las relaciones de y con extranjeros—; ese mismo *ius civile*, proveniente de la interpretación jurisprudencial y de la legislación, y enriquecido con instituciones del *ius gentium*, aparece enfrentado al *ius honorarium*, originado en la función jurisdiccional del pretor; las *leges* —producto del poder legislativo del emperador— como antinomia de los *iura**, expresión, a través de las obras de juristas, de todo el derecho anterior, etcétera.

(D) Derecho de juristas. — Tiene su base en el hecho de que la fuente más importante del derecho preclásico y clásico son las opiniones y dictámenes de individuos privados, sin otro fundamento que el de su prestigio y la adecuación de sus soluciones a la vida social, las que adquirirían directamente valor normativo y vinculatorio para los órganos judiciales sin necesidad de pasar previamente por los órganos legislativos estatales.

(E) Sentido de la realidad. — Los juristas mantenían contacto constante con la realidad y la conciencia social, situándose al margen de ideologías y utopías.

(F) Tipicidad de las instituciones. — Los romanos, de espíritu real y concreto, si bien superaron el tratamiento casuístico, no llegaron a las formulaciones extremadamente abstractas de las teorías generales —de la magistratura, de los contratos, de la servidumbre, etcétera—, sino que centraron su atención en el estudio de los tipos, es decir, de cada tipo de ins-

titud. Esto significó un razonable término medio entre un empírico casuismo y un abstracto conceptualismo generalizante.

(G) Falta de codificación. — Una codificación que cubriera la totalidad de la vida jurídica hubiera parecido a los romanos cristalizar o anquilosar un proceso de desarrollo que su experiencia les mostraba incesante.

(H) Tendencia a la universalidad. — Como producto de la expansión política y cultural romana y la paulatina integración con tantos pueblos.

PERIÓDOS HISTÓRICOS

Toda división en períodos de un proceso histórico es siempre arbitraria y relativa, pero es un recurso metodológico y didáctico.

La división tradicional en período monárquico, republicano e imperial, está referida a la organización del poder político en su más conspicua manifestación. Pero en el caso de Roma, además de esa referencia, conviene tener en cuenta la composición humana del estado y la organización del ámbito hegemónico.

(A) La organización política del pueblo romano. — Se ha comprobado la existencia de un *rex* en la primitiva confederación de grupos que dio origen a Roma. Se produce en el siglo VI una reacción patricia contra la creciente preponderancia real y luego de un período de transición se desemboca en un régimen que se ha denominado republicano, que tendrá una época de asentamiento y otra de equilibrada plenitud; posteriormente el crecimiento del estado y la falencia de sus órganos —propios de una pequeña comunidad— para gobernar un enorme imperio, producirá una crisis de la que se saldrá con la constitución de un poder monárquico burocrático que superará las limitaciones de los órganos de la ciudad estado.

Durante los dos primeros siglos, este poder aparecerá limitado por la subsistencia formal pero decadente de los antiguos

órganos republicanos. A principios del siglo III se acentúa el carácter autocrático y militarista del régimen que devendrá una férrea y absoluta monarquía al frente de una omnipresente y centralizada burocracia. El Imperio se dividirá en la parte oriental —cuya capital, Constantinopla, durará hasta 1453— y en la occidental, que subsistirá formalmente hasta el 476 d.C., para quedar fragmentada en varios reinos bárbaros.

(B) Integración del cuerpo cívico del estado. — En los primeros tiempos, únicamente los quirites * o patricios * integraban los cuerpos cívicos de Roma. Los otros hombres libres, los plebeyos, fueron logrando su paulatina inserción al actuar en el ejército y participar en los comicios centuriados.

Se añadirán luego contingentes latinos que Roma anexa. Superada la crisis de la Guerra Social *, se consiente en conceder status romano a los miembros de las comunidades itálicas de gran parte de la península.

Luego se irá concediendo la ciudadanía a las elites gobernantes de las ciudades del Imperio y, por último, se la otorgará masivamente a casi todos los hombres libres de éste (año 212 d.C.).

(C) Organización del ámbito hegemónico. — Existieron factores que tendían a conservar el estado romano en su estructura originaria de ciudad estado, retardando la formación del estado universal que fue el Imperio, tales como: 1) la concepción de la ciudad estado como única forma de *libera res publica* (estado libre); 2) el egoísmo de la oligarquía y del pueblo de Roma a extender a otros la condición de ciudadanos.

A su vez, otros factores se opusieron a éstos y lograron conformar la nivelación geopolítica del Imperio: 1) la composición del ejército, paulatinamente más abierto a los aliados, a los peregrinos y por último a los bárbaros; 2) el plácido realismo romano en lo político y administrativo; 3) la tendencia de los emperadores a legislar uniformemente para todo el imperio; 4) el impulso expansivo de la burocracia *.

PROPUESTA PARA UNA DIVISION DE LA HISTORIA ROMANA

I. Un período inicial, el de la ciudad quiritaria, que abarque la formación de la ciudad estado, la influencia etrusca que organiza y perfecciona la *civitas* *; la reacción patricia contra el *rex* y su esfuerzo por mantener sus privilegios ante la cada vez más numerosa plebe, la reacción de ésta y su trabajosa integración a los cuadros sociales y políticos romanos, y la conformación del régimen político de la *res publica* *.

II. Un segundo período —el de la *res publica*— se iniciaría con un teñidura al armónico funcionamiento de magistraturas, Senado comicios. Este período terminará en una crisis, producto de la antifuncionalidad de los órganos políticos de la ciudad estado para gobernar toda la cuenca del Mediterráneo, que se hallaba bajo la hegemonía romana, ya sea por alianzas o dominio directo.

III. Una tercera etapa —la del Principado— estaría caracterizada por el creciente aumento del poder autocrático del *princeps* y la formación de una estructura burocrática en detrimento de los órganos republicanos que subsistían formalmente. Se da entonces una extensión de la ciudadanía a todo el Imperio y una uniformidad en su organización administrativa.

IV. El Dominado, la cuarta etapa, que comienza en el año 284 d.C. se caracterizó por un despotismo teocrático, una concepción totalitaria de la sociedad y un estado universal. Luego de una definitiva división del imperio (395 d.C.), la parte occidental se fragmentará en varios reinos bárbaros (476 d.C.), mientras que la oriental logrará sobrevivir hasta 1453.

VER LÁMINA NÚMERO UNO.

DISTINTAS PROPUESTAS DE PERIODIZACION DEL DERECHO ROMANO

I. Hugo, asimilando la vida del Derecho Romano a la de una persona, la divide en (A) infancia, desde la fundación de

Roma hasta la ley de las XII tablas (451 a.C.); (B) juventud, hasta Cicerón (mediados del siglo I a.C.); (C) virilidad, hasta Alejandro Severo (235 d.C.); (D) vejez, hasta la muerte de Justiniano (565 d.C.).

II. Bonfante y De Francisci fijan la periodización alrededor de dos momentos de profunda crisis de transformación —el fin de la segunda guerra púnica y el del reinado de Alejandro Severo—: (A) derecho quiritarario, hasta el 202 a.C.; (B) derecho romano universal o *ius gentium* hasta el 235 d.C.; (C) derecho heleno romano o *romeo*, hasta el 565 d.C.

III. Perozzi simplifica: (A) período romano, hasta el 250 d.C.; (B) período romano-helénico, hasta el 565 d.C.

IV. Riccobono, entre otras propuestas, presenta una tripartita: (A) derecho nacional romano, hasta el establecimiento total de la hegemonía en el Mediterráneo (146 a.C.); (B) derecho universal, hasta el fin de la persecución de los cristianos (305 d.C.); (C) derecho romano-cristiano, hasta la muerte de Justiniano.

V. Biondi propone una partición quintuple: (A) hasta antes de la ley de las XII tablas; (B) hasta el fin de la *res publica*; (C) hasta el advenimiento de Constantino (306 d.C.); (D) hasta inmediatamente antes de la compilación justiniana; (E) hasta la muerte de Justiniano.

VI. En este libro se adopta la división propuesta por Guarino, la que coincide con la ya vista división de los períodos de la historia de Roma: (A) derecho arcaico, correspondiente al período de la ciudad quiritaria; (B) derecho preclásico, al de la *res publica*; (C) derecho clásico, al del Principado; (D) derecho posclásico, al del Dominado.

- * En gráfico de págs. 8 y 9 se ve que los momentos históricos más tenidos en cuenta para las divisiones son (A) el de las XII tablas; (B) el de la segunda guerra púnica; (C) el del comienzo del Principado; (D) el fin de la dinastía de los Severos; (E) el de la época de Diocleciano y Constantino.

CAPITULO II

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES POLITICO-SOCIALES ROMANAS

LA CIUDAD QUIRITARIA

LOS ORIGENES Y LOS REGES

En el relato tradicional de los orígenes de Roma se confunden los elementos legendarios con circunstancias y hechos que la ciencia moderna está confirmando, como la existencia de grupos migratorios e influencias culturales provenientes del Egeo y el Asia Menor, la fusión de stirpes sabinas y latinas, e predominio etrusco, el régimen monárquico y su crisis.

LEYENDA Años a. C. HISTORIA

El príncipe troyano Eneas logra huir con sus hombres de la destrucción de la ciudad. Luego de arduas peripecias en el Mediterráneo y de su frustrada relación con Dido, reina de Cartago, llega al Lacio, donde luego de luchar con una coalición de pueblos, entre ellos los etruscos, desposa a Lavinia, hija del rey autóctono Latino.

Ascanio, hijo de Eneas, funda a su muerte la ciudad de Alba Longa.

- 1000 Alrededor de los siglos X y XI a. C. aparecen configuradas pequeñas unidades sociopolíticas —grupos gentilicios?— en el Lacio, instaladas en aldeas con, probablemente, una acrópolis —posición fortificada—. Se organizan en ligas o confederaciones por motivos de defensa y religiosos, sin llegar a constituir una unidad política superior. Por la arqueología se constata una aldea de pastores en el Cermal, situado en el monte Palatino.
- 900
- 800 La federación latina del *Septimontium* abarca tres de las siete colinas de Roma.
- 753 Tres caseríos latinos del monte Palatino forman la llamada *Roma Quadrata*, al enmarcarse con un terraplén de tierra, piedras y troncos.
- Los latinos parecen tener buenas relaciones con poblados sabinos, como lo probarían tumbas promiscuas de inhumación —sabinas— y de incineración —latinas— en la necrópolis ubicada en la depresión donde luego estará el Foro, fuera de los muros de la *Roma Quadrata*.
- 700 La futura Roma se beneficia con la derrota de Alba Longa, que tal vez abre las puertas a la penetración etrusca.
- 600 Los etruscos, buscando consolidar su dominio en Toscana y
- Rómulo y Remo, nietos de Nómator, decimotercer rey de Alba Longa, fundarán una nueva ciudad: Roma.
- Rómulo, jefe de la flamante comunidad, crea un consejo de 100 *patres*, cuyos descendientes son los patricios.
- La población de Roma se completa con el rapto de las sabinas y la posterior unión con la comunidad sabina.
- Al desaparecer Rómulo en pasmosas circunstancias, accede al trono el sabino Numa Pompilio, quien organiza los ritos, el calendario y los colegios sacerdotales. Es sucedido, luego de 43 años de reinado, por Tulio Hostilio, de origen latino, quien destruye Alba Longa y traslada a Roma a sus habitantes. A continuación el sabino Anco Marcio funda el puerto de Ostia.
- Tarquino, procedente de Etruria, llega al poder e inicia obras

de urbanización y vence a otros pueblos latinos y sabinos. Su yerno, Servio Tulio, construye el primer muro de cintura de Roma, divide la ciudad en cuatro circunscripciones y a la población, según su posición económica, en cinco clases y la distribuye en centurias. Un yerno de Servio Tulio, hijo de Tarquino y apodado el Soberbio, tras asesinar al suegro toma el poder ejerciéndolo típicamente y realiza obras como la Cloaca Máxima y el templo de Júpiter Capitolino.

Ante los abusos de Tarquino y su familia el pueblo reacciona y los expulsa. Reunidas las centurias, son elegidos los primeros consules, Junio Bruto y Tarquino Collatino, líderes del movimiento revolucionario.

509

Campania, perfeccionan la federación latino-sabina, creando las condiciones para una cultura urbana, y "fundan" realmente la ciudad, imponiéndola sobre las antiguas estructuras políticas, las gentes y las ligas. Ello se perfeccionará con el comicio curiado, las cuatro tribus territoriales y la organización timocrática * que dará un ejército y un ordenamiento cívico que hará obsoletas las estructuras gentilicias.

El despojar al rey de sus poderes cívico-militares se debe a una reacción de la aristocracia gentilicia contra un poder incrementado por (A) la transferencia de atributos soberanos de los grupos gentilicios confederados a los órganos unitarios de la ciudad y (B) el carácter militar del *imperium* * introducido por los etruscos. El *rex*, reducido a funciones religiosas, desaparecerá de la escena histórica.

LA GENS

Constituía en tiempos de la formación de Roma un grupo humano primordial, de unidad política, comunidad económica, religiosa y jurídica y con fuertes lazos de solidaridad social.

I. Para algunos autores, las gentes romanas, en cuanto pretendían tener un antepasado único —o héroe fundador—, tenían un origen y desarrollo genético familiar; para otros, las gentes serían el resultado de un proceso asociativo político. La gens

configuraba una unidad preestatal en la cual ya encontramos presentes los elementos que componen al estado moderno: un territorio propio, órganos de gobierno —la asamblea y el *pater* o jefe de la *gens*— y normas de conducta —las *mores* * *maiorum* (costumbres de los antepasados).

- Políticamente actuaban en forma soberana en lo referente a sus relaciones exteriores y a su ordenamiento interno. En lo económico llevaban a cabo un elemental régimen de autoabastecimiento. La comunidad religiosa se patentizaba en la existencia de los *sacra gentilicia* (cultos o ritos privativos de la *gens*).
- Existía también un complejo normativo propio y exclusivo de cada *gens*: sus *gentilitatis*.
- La solidaridad gentilicia hacía aparecer al grupo como un todo único; como un sujeto activo o pasivo de la venganza de una ofensa sufrida o inferida, respectivamente, por un miembro de la *gens*. Se evidenciaba en el uso del *nomen**, en el sepulcro común, en el derecho hereditario y en la tutela y curatela.

II. Además de los gentiles, integraban la *gens* los *clientes* —de *clueve* (obedecer) — adscriptos voluntaria o compulsivamente a una condición de dependencia o vasallaje.

El *patronus* —jefe de la *gens*— debía protección al cliente y le entregaba en carácter precario * —ante la plegaria o ruego (*precaria*)— tierras para su trabajo; el cliente debía obediencia, asistencia armada y política, jornadas de trabajo y, en casos determinados, contribuciones económicas.

La única forma de tener acceso a la tierra y protección había sido, pues, pertenecer a una *gens*, ya sea como gentil o como cliente.

III. La *gens*, naturalmente, fue perdiendo vigencia y razón de ser cuando la *civitas* empezó a tomar a su cargo la protección del individuo al margen de los cuadros gentilicios y a integrar a los *cives* por medio de instituciones políticas tales como el Senado, los comicios, las magistraturas, los colegios sacerdotales y el ejército ciudadano.

En el siglo I a.C. la *gens* —ya sin vigencia ni relevancia jurídica— era un conjunto de individuos que sólo tenían en común un *nomen**, remanente de una primitiva creencia en un antepasado también común.

LAS TRIBUS

Las tres tribus gentilicias. — Se puede utilizar la palabra tribu con dos sentidos: 1) como unidad política de base étnico-cultural; 2) como unidad resultante de una división administrativa de una comunidad.

I. La interpretación tradicional da la primera acepción a las legendarias tres tribus romanas: los ramnes serían los latinos, los titienses los sabinos y los luceres los etruscos. Serían pues unidades precívicas cuya unión, precisamente, originó a Roma.

II. Otros autores las consideran, en cambio, en la segunda acepción: serían una subdivisión artificial o convencional hecha con posterioridad a la existencia de la *civitas*. Así parecería sugerirlo el probable origen etrusco de sus nombres y la simétrica división de cada tribu en diez curias y el exacto aporte de cien caballeros y mil infantes por cada tribu.

Las cuatro tribus territoriales. — El ordenamiento de Servio Tulio, se dividió la ciudad en cuatro tribus territoriales, parece haber sido orientado a incluir a pobladores que no estaban encuadrados en *gentes*: precisamente aquellos que constituirían el núcleo de la futura plebe. Sería un progreso de la *civitas*, la nueva realidad estatal, sobre las antiguas unidades políticas basadas en las relaciones de parentesco —las *gentes*.

LAS CURIAS Y EL COMICIO CURIADO

En el proceso de superación de la estructura gentilicia por esquemas estatales de integración cívica, los comicios curiados tienen un papel primordial.

Constituyen el paso inicial de la formación de lo que se llamará el *populus**, palabra con que originalmente se designaba al ejército formado por los integrantes de la *civitas* y que luego —a través de la estructura centuriada— pasó a significar la ciudadanía encuadrada en los comicios.

Las otras instancias en la formación del *populus* fueron la introducción del principio territorial —las cuatro tribus— y el sistema timocrático —las *clases* y las *centurias*— que acabaron por disolver las estructuras gentilicias para integrar al ciudadano a la *civitas* por sus condiciones o circunstancias propias —patrimonio y domicilio— y no por su pertenencia a grupos precívicos.

I. Tradicionalmente se habla de la existencia de 30 curias, 10 por cada una de las tres tribus. Criterios modernos hacen aparecer a la curia como una agrupación de *gentes* vinculadas sobre la base de un principio novedoso para la época: el de la vecindad de asentamiento.

II. Las dos primordiales funciones que se le atribuyen a esa "reunión de varones" —*curia* provendría de *coviria*, palabra formada por *co*: en conjunto, y *viri*: varones— eran (A) el reclutamiento militar —100 infantes y 10 jinetes por curia— y (B) funciones comiciales.

Estas últimas eran 1) el reconocimiento del *imperium* * del *rex* —posteriormente, de los magistrados *cum imperio*— por la *lex curiata de imperio* (ley curiada acerca del imperio), manifestado por el *suffragium* o aclamación unida al ruido (*frágor*) producido por el golpear de las armas; 2) el control de los actos e intereses de *gentes* y familias: testamento *, adrogación *, *cooptatio* o admisión en la *civitas* de una *gens* extraña, etcétera; y 3) reuniones para información acerca de asuntos de interés público.

EL SENADO

Primitivamente el Senado estaba compuesto por los *patres gentis*, cabezas de la confederación de *gentes* que constituyó el origen de la *civitas*.

Al incrementarse por la influencia etrusca el poder real, el *rex* empezó a incluir en el Senado a otros *patresfamilias* *, ya no como representantes grupales, sino como miembros de una comunidad unitaria.

LA CIUDAD QUIRITARIA

EL REX

El *rex* —del latín *regere* (ordenar, dirigir)—, en la primera época vio su accionar muy condicionado por la existencia independiente de las *gentes*.

Al superarse los esquemas federativos en favor de la unidad estatal, que en cierta forma representaba el *rex*, éste fue cobrando una especial preponderancia, incrementada por el ordenamiento de la *civitas* y la reforma militar etrusca. El *imperium* real, que superó barreras consuetudinarias, fue sentido por los patricios como tiránico y motivó la conocida reacción.

El *imperium*. — Es un tipo especial de poder que tuvo el *rex* y luego los principales magistrados de la *res publica*. La posible etimología —*imparare* (preparar las filas de los soldados)— nos daría una clave de lo que debe de haber sido el origen del *imperium*, que tradicionalmente es tomado como un poder originario, unitario, absoluto y soberano.

- Soberano (*superanus*) por ser superior, por estar por encima de cualquier otro.
- Absoluto, por no estar limitado o relativizado por nada.
- Unitario, porque no es una adición de determinadas atribuciones parciales, sino una masa total de poder.
- Originario, porque no se deriva de otra fuente —por ejemplo, un mandato popular—, sino que halla su razón de ser en la misma institución de la *arquitectura* o de la magistratura.

Al poder, originariamente sacerdotal del *rex* latino-sabino y militar del etrusco, se le habrían adosado, con el tiempo, otras atribuciones, impuestas por la cada vez más compleja vida política de la *civitas*.

Colaboradores reales. — Debido a ella, precisamente, el *rex* debió delegar ciertas funciones:

- 1) el *praeфекtus urbis* quedaba al frente de la ciudad cuando el *rex* se ausentaba;
- 2) los *duoviri perduellionis* (dos varones de la traición al estado) se encargaban de la instrucción del proceso y de la ejecución de los acusados de alta traición;
- 3) los *quaestores parricidii* (inquisidores del *parricidium*)

actuaban en la instrucción del proceso y la ejecución de los asesinatos de un *paterfamilias*.

4) los *tribuni celerum* (tribunos de los veloces) comandaban la caballería.

5) el *magister populi* (jefe del ejército) o el *praetor* (el que marcha al frente) o los *tribuni militum* (tribunos de los soldados) eran puestos por el rey al frente del ejército.

COLEGIOS SACERDOTALES

Los distintos colegios sacerdotales cumplen las funciones o armonía de la *civitas* a la voluntad u ordenamientos de la divinidad.

I. Los augures asesoran al *rex* o al magistrado en su interpretación de los auspicios o augurios por los que la divinidad manifiesta su buena o mala disposición ante un quehacer comunitario: una elección, una inauguración de un templo, la iniciación de una batalla, etcétera.

II. Los pontífices asisten y supervisan todos los actos sacrales públicos y privados, llevan el archivo y registro de los principales acontecimientos y son los intérpretes de las *mores maiorum*.

III. Los feciales se ocupan de todos los ritos referidos a las relaciones internacionales: iniciación de hostilidades, concertación de tratados, fijación de límites, etcétera.

IV. Los tres flamines, encargados de los cultos capitolinos, oficiaban en la *conferreatio* *.

LA CIVITAS PATRICIA Y LA TRANSICIÓN A LA RES PUBLICA

CIVITAS

Palabra derivada de *civis* (ciudadano, miembro de una comunidad) indica ciudadanía en sus dos acepciones: (A) cualidad o condición de *civis*; (B) conjunto o universalidad de todos los *cives*.

LA CIUDAD QUIRITARIA

A) De la condición de ciudadanía se trata en el Capítulo V.

B) *Civitas*, como concepto jurídico, es un ente unitario, persona ideal distinta de los *cives* que la integran; como realidad política que se dio en la historia del Mediterráneo, equivale plenamente a lo que los griegos denominaban *polis*: una sociedad de hombres libres organizados para una vida política soberana, una ciudad estado.

* Se trata de un conjunto de hombres ocupantes de un territorio relativamente pequeño —cabían cientos de ellos en las penínsulas helénica e itálica— con, por lo menos, un centro cívico en que puedan funcionar los órganos de gobierno: un conjunto de magistrados, un consejo de notables o de ex magistrados y la asamblea de todos los que están en condiciones de cumplir con el deber esencial de defender la comunidad.

Hay correlación entre la condición de ciudadanía, la posesión de la tierra y el deber del servicio de armas: les parecía equitativo que quien más tierra poseía, mayor contribución debía en la emergencia bélica y mayor peso le correspondía en la decisión política. La organización timocrática * institucionalizaba este principio al atribuir, según la posición económica, una mayor o menor participación en la guerra y en la vida política.

PROCESOS QUE LLEVAN A LA ESTRUCTURACIÓN DE LA RES PUBLICA

La *civitas* que había resultado de los sinecismos de los grupos gentilicios latinos y sabines y de la presencia de una clase dirigente etrusca puede denominarse patricia porque sólo los llamados patricios eran plenamente integrantes de ella: el resto de los hombres libres romanos, quienes constituirán, a partir de la terminación del sistema real, la plebe, sólo en parte se hallaban incorporados a la estructura cívica.

Para que pueda considerarse que existe lo que los romanos llamaron *res publica* entendemos que no basta aquella caída de la monarquía: tendrán (A) que integrarse patricios y plebeyos en plano de igualdad jurídica, social y política, (B) que constituirse el *populus* como órgano activo de la *civitas* en su expresión comicial, (C) que regularizarse el ejercicio del *imperium* del *rex* en el tradicional régimen de los dos cónsules con recíproco derecho de *intercessio* * (veto).

Ello se realizó en tres paralelos e interrelacionados procesos que pueden darse por completados, en lo esencial, allá por el año 367 a.C., que ya se ha consignado como fecha límite de la *civitas* patricia con la *res publica*.

CONFLICTO E INTEGRACIÓN PATRICIO-PLEBEYA

Siglo y medio de la historia interna de Roma está cubierto por la oposición que se perfila, desde la caída de la monarquía, entre patricios y plebeyos y por la trabajosa serie de conflictos y transacciones que llevó a la integración de unos y otros en el *ius romanus*.

Origen de la distinción entre patricios y plebeyos, muy controvertido, ha dado lugar a numerosas, variadas y hasta contradictorias tesis.

De todos modos, en forma general y conciliando eclécticamente aquellas tesis, pueden establecerse estos puntos.

I. Los patricios son los descendientes de los grupos gentilicios cuyo sinecismo originó la *civitas*. Esos grupos habían aceptado el ingreso en su comunidad de otros llegados posteriormente. Tal el caso de los etruscos, que llegaron a acceder al poder real.

II. Los plebeyos se definen por exclusión: son los hombres libres romanos que no pertenecen a los grupos familiares patricios. Son de variada procedencia y al momento de la caída de la monarquía no tienen nada en común ni conciencia de clase.

III. Es probable que haya existido como núcleo básico una o varias comunidades vencidas y trasplantadas en el Aventino. Tal vez el poder contar con la protección jurídica y las posibilidades económicas que brindaba la nueva realidad política, la *civitas*, haya estimulado la inmigración de individuos y la salida de clientes de su estado de dependencia con respecto a las *gentes*.

IV. Todo ese elemento humano había quedado implicado en el proceso de unidad cívica que perfeccionaron los etruscos, pero no poseían el poder político ni paridad social, ni jurídica, ni religiosa con los patricios.

V. La reacción patricia que privó al *rex* etrusco de sus poderes políticos y militares significó también una política de re-

tracción económica y de monopolio patricio en la apropiación de la tierra. Ello contribuyó a crear una conciencia de unidad de intereses entre esos grupos heterogéneos. Algunas de cuyas familias, con algún bienestar económico y prestigio, se pusieron a la cabeza de lo que se organizó como una comunidad política —la plebe— para actuar dentro de otra —la *civitas*.

Conflicto e integración. — El recurso principal de la plebe fue la amenaza de secesión o la negativa de colaboración. La plebe se dio sus jefes, los tribunos, a los que protegió con un compromiso jurado de considerar *sacer* * (sacrilego) —y pasible, por ende, de muerte— a todo aquel que atacara u obstaculizara a un tribuno.

El estado patricio fue reconociendo la legitimidad del accionar de los órganos de la plebe, tanto los tribunos, como los ediles, como los concilios de la plebe y su expresión, el plebiscito.

Y fue negociando con transacciones y retaceos los objetivos que se proponía la plebe.

- * En el 450 a.C. se habría concretado con la ley de las XII tablas una base de igual régimen normativo para patricios y plebeyos.
- * En el 449 la *lex Valeria Horatia* institucionalizó la inviolabilidad de los tribunos de la plebe.
- * En el 445 la *lex Canuleia* admite el *connubium* * entre patricios y plebeyos.
- * Cualquiera haya sido la época en que se instauró el sistema centuriado, la última transformación de éste en un regular órgano de manifestación de la voluntad ciudadana fue incrementando el peso político de los plebeyos, que desde el comienzo habían sido convocados a integrarlo.
- * En el 409 se abre para los caudillos de la plebe el *cursus honorum* *: pueden ser elegidos cuestores. En el 400, llegan a integrar, en parte, el tribunado militar.

Las más significativas conquistas se logran en el 367 por leyes obtenidas por los tribunos Licinio Stolo y Sextio Laterano: (A) queda instituida definitivamente la magistratura colegiada formada por dos cónsules, de los cuales uno podía ser plebeyo; (B) la función jurisdiccional se desglosa de aquella suprema magistratura y se la confía a un *collega minor* patricio, con el antiguo nombre militar de *praetor*; (C) queda reglamentada la distribución del *ager publicus* * tanto a patricios como a plebeyos.

LA FORMACION DEL POPULUS

Hay una doble evolución: (A) la que lleva de un ordenamiento todavía gentilicio —comicio curiado— a uno enteramente ciudadano —el comicio centuriado—; (B) la que lleva de una reunión de los ciudadanos en armas para recibir informaciones u órdenes a una asamblea política con poder soberano de aprobar o rechazar leyes y medidas y de elegir a los magistrados.

- La organización timocrática del comicio centuriado es debida, tal vez, a la influencia etrusca y está, sin duda, alineada en una contemporánea tendencia, común a casi todas las ciudades estados mediterráneas, que substituye combates de aristócratas guerreros —como los descritos en la Iliada— por choques masivos de formaciones cerradas de ciudadanos no profesionales en el uso de las armas. Esa organización se basa en la división de los ciudadanos en *classes* (levas o conscripciones) según su status económico: una *classis* de *equites* (jinetes), cinco *classes* de *pedites* (infantes) y una masa de *proletarii* (que sólo cuentan con prole), etcétera. Para cada *classis* hay un número fijo de centurias integradas por un número variable de ciudadanos, de modo tal que las centurias de las *classes* más pudientes son más y con menos integrantes, por lo que estos últimos tienen, en un sistema electoral de segundo grado un voto de mayor gravitación que el de los otros ciudadanos.
- El ejército ciudadano organizado así, por centurias, comenzó a ser auscultado en su sentir —*suffragium*—; paulatinamente, la consulta se fue institucionalizando en forma de una votación para aprobar o desechar leyes y candidaturas propuestas por el magistrado convocante. Cuando el ejército tuvo otra estructuración, subsistió el sistema centuriado para la asamblea (*comitium*) de decisión política.

LOS HEREDEROS DEL IMPERIUM

La historia legendaria de los romanos relata que el mismo día de la expulsión de Tarquino el Soberbio el pueblo eligió dos cónsules para reemplazarlo en el ejercicio del *imperium*.*

Hoy en día se piensa que sólo se puede estar seguro de la existencia de esa magistratura colegiada a partir del 367 a.C., cuando se habría instituido, precisamente, para dar una forma de equiparación política entre patricios y plebeyos.

- Hasta entonces se sabe que existieron distintos tipos de magistraturas con un único titular o con varios de ellos: el *magister populi* (jefe del ejército) o dictador, los *tribuni consulari potestate* (tribunos de potestad consular), los *decemviri**, etcétera, y, tal vez, cónsules o *praetores*.
- Probablemente, año a año, se determinaba que tipo de magistratura era conveniente según las circunstancias políticas y bélicas.

RES PUBLICA

Los romanos aludieron a lo que nosotros llamamos estado, como al conjunto de intereses y atributos que pertenecía al *populus*, personificación de la comunidad; hablaron así de *res populi* (lo que es del *populus*) o *res publica*.

En un sentido genérico, *res publica* significaba "organización constitucional del *populus*".

Pero en un sentido específico, los romanos designaron con ese nombre al concreto régimen político romano que, según la historia tradicional, tuvo su comienzo inmediatamente después de la expulsión de Tarquino el Soberbio, y que, según el criterio seguido en esta obra, sólo queda estructurado en el 367, con la integración patricio-plebea perfeccionada con la magistratura colegiada de dos cónsules elegidos por un *populus* que ha completado su evolución como órgano de expresión de la voluntad ciudadana.

CARACTERES DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA RES PUBLICA

I. Nunca se cristalizó en un cuerpo normativo cerrado y rígido, como el de las constituciones de las repúblicas americana. Tuvo un desarrollo consuetudinario con sólo unas pocas leyes fundamentales.

II. La *res publica romana* es una variante del tipo *civitas**, con sus años que mantendrán su funcionamiento original, aunque éste resulte insuficiente y falseado por el exorbitante territorio que ninguna otra *civitas* experimentó.

III. Aunque el manejo de la *res publica* estuvo teóricamente abierto a todos los *cives optimo iure**, el régimen no resultó democrático (A) porque, si bien la voluntad del *populus* se fue considerando soberana, fueron los otros dos órganos los que tuvieron la facultad de dar o no ocasión a que esa voluntad se manifestara, (B) porque la organización timocrática* de los

comicios y su sistema de votación indirecta daba mayor gravitación a los ciudadanos de mejor situación económica, (C) porque, aun cuando elegidos por el comicio, el poder de los magistrados se consideraba no derivado de esa elección, sino insito originariamente en el órgano comunitario.

IV. La *res publica* era esencialmente aristocrática, en tanto dirigida por una elite de familias patricias y plebeyas que integraban las magistraturas y el Senado (A) en razón del carácter honorario de la función pública y de los gastos requeridos en una campaña electoral, (B) por el apoyo de las clientelas, (C) y porque la ciudadanía confiaba en los hombres surgidos de ámbitos de experiencia y tradición de gobierno.

PERIODOS DE LA RES PUBLICA

La evolución de la vida institucional de la *res publica* puede caracterizarse distinguiendo cinco periodos:

- 1) de perfeccionamiento de la integración patricio-plebea —367 a 287 a.C.—;
- 2) de equilibrio funcional de la *civitas* —287 a 218 a.C.—;
- 3) de preponderancia de la política imperialista —218 a 133 a.C.—;
- 4) de crisis de la *res publica* —133 a 49 a.C.— y
- 5) de guerras civiles —49 a 27 a.C.—.

PERFECCIONAMIENTO DE LA INTEGRACION PATRICIO-PLEBEYA

- Los plebeyos, a través de su acceso a las magistraturas, el Senado y se institucionaliza así una nueva senatorial, que se enriquecerá también con el apogeo de las comunidades anexadas.
- En el 339 a.C. se reconoce como norma de la ley siempre que sea confirmado por la *auctoritas* * por este requisito es removido por la *lex Hortensia* *
- La interpretación del derecho deja de ser un monopolio el colegio de los pontífices que empieza, por lo demás, a admitir a plebeyos en su seno.

RES PUBLICA

EQUILIBRIO FUNCIONAL DE LA CIVITAS

- Se ha consolidado la influencia democrática del *populus* a través de la constitución de una sólida clase media de pequeños propietarios rurales, de la atenuación del principio timocrático producida por la reforma hecha al comicio centuriado, del *cursus honorum*, y de la supresión de la *auctoritas patrum*.
- Pero el Senado, único con posibilidades de elaborar y dirigir una política permanente y de largas miras, atempera aquella influencia democrática. Parece justificarse la idealizada caracterización que haría luego Polibio de la *res publica romana* como una constitución mixta en la que se armonizan los aspectos más positivos del poder monárquico —el del magistrado—, del aristocrático —el del Senado— y del democrático —el de los comicios.

De todos modos es el momento histórico en que la realidad social y política de Roma corresponde perfectamente a los esquemas estructurales de la *civitas*, *polis* o ciudad estado.

a expansión romana irá forzando aquella correspondencia y posteriormente distorsionando el funcionamiento de los órganos cívicos que se corromperán y desacreditarán en la infuncionalidad y falta de representatividad.

VER ÁMINA NÚMERO DOS.

PREPONDERANCIA DE LA POLITICA IMPERIALISTA

Periodo caracterizado por (A) el impulso imperialista y tendencias oligárquicas de la clase senatorial, (B) la formación de la clase ecuestre, (C) la ruina del campesinado medio, (D) el auge de la economía esclavista, y (E) la gravitante influencia de elementos culturales foráneos.

- (A) La hegemonía lograda por Roma en la península itálica no había sido ni planeada ni basada en la explotación; el triunfo sobre Cartago abrió las posibilidades para una agresiva política de expansión en el Mediterráneo, que llevó a cabo la clase dirigente senatorial.
- (B) La misma política imperialista con sus oportunidades financieras y comerciales dio lugar al surgimiento de una nueva clase, la de los

caballeros —porque se acostumbró a censarlos en las centurias ecuestres—, la que se institucionalizó a partir de la *lex Claudia* (218 a.C.), que separaba a la clase senatorial —las familias que habían contado o contaban con un miembro en el Senado— del comercio marítimo y de las licitaciones públicas. El gran comercio y la organización financiera del Imperio quedarán en manos de poderosas sociedades de miembros de la nueva clase ecuestre llamados publicanos, por actuar en negocios públicos de licitaciones para la percepción de impuestos, la construcción de obras públicas, los suministros bélicos, la explotación del *ager publicus*, los empréstitos a las comunidades vencidas para que pagaran sus contribuciones de guerra, etcétera.

• (C) El campesinado romano quedó arruinado 1) por su peregrinar bélico, que lo obligó a descuidar sus tierras y contraer deudas; 2) por la ruinosa competencia de la mano de obra servil; 3) por la afluencia de grano barato de las regiones conquistadas y por su imposibilidad de volcarse hacia el cultivo de la vid y el olivo, como lo hizo la pudiente clase senatorial, que podía esperar por largos años la evolución del ciclo productivo, y 4) por la política senatorial de no distribuir el *ager publicus* y dejarlo abierto a la ocupación de las familias pudientes, que pudieron así —y con la compra de tierras de campesinos arruinados— constituir grandes latifundios trabajados por cuadrillas de esclavos.

• (D) Las guerras de conquistas incrementaron exorbitantemente el número de nuevos esclavos, cuya explotación masiva y brutal habría de provocar frecuentes y serias sublevaciones, reprimidas severamente.

• (E) Roma, abierta a la penetración de cultos orientales y a la influencia del pensamiento e individualismo helénico, sufrió profundas transformaciones culturales, especialmente en las costumbres y valoraciones de su clase

CRISIS DE LA

Los enormes intereses económicos y políticos de un imperio de cincuenta millones de habitantes confluendo sobre los órganos de gobierno de una ciudad estado no podían menos que distorsionarlos y corromperlos: los hombres de la clase senatorial entregados al juego de conseguir a cualquier costo las magistraturas para acceder consecuentemente a las promagistraturas, esquilmar entonces a las provincias, para, de nuevo, poder volcar a la palestra electoral ingentes riquezas en busca de nuevas magistraturas...; la clase ecuestre, abroquelada en su poder económico, buscando controlar el poder político; las clases proletarias oscilando entre la corrupción electoral y el servicio mercenario en ejércitos adheridos al éxito de sus jefes, poli-

ticos que habían conseguido ser elegidos para un *imperium extraordinarium*, es decir, otorgado a quien no es magistrado ni promagistrado.

Los momentos más significativos de la crisis institucional son (A) el fracaso de los Gracos por reconstruir la clase media campesina y por democratizar el gobierno a través de una más frecuente consulta a los comicios; (B) la conversión de un ejército cívico en uno de enganchados; (C) la Guerra Social y la ampliación de la ciudad estado Roma a casi toda la península itálica; (D) la restauración oligárquica promovida por Sila y jaqueada por la práctica de los *imperia extraordinaria*.

• (A) Tiberio y Cayo Graco, utilizando al tribunal de la plebe en su primigenio papel revolucionario, tienden, con distintos resultados, a 1) recrear el sano y fuerte núcleo de pequeños propietarios rurales a través de una reforma agraria que, limitando la extensión del *ager occupatorius* en manos de la oligarquía, distribuía pequeñas parcelas a los proletarios; 2) conseguir el apoyo de la clase ecuestre haciéndola participar de la administración de justicia; 3) robustecer, con instituciones como la *obrogatio**, la tendencia al predominio de la voluntad del *populus* sobre la magistratura y el Senado; 4) extender la ciudadanía romana a los latinos y la condición latina* a los itálicos.

• (B) Las legiones romanas se constituían, en cada emergencia, por la leva de ciudadanos de las cinco clases del sistema centuriado. Las comandaban los cónsules asistidos por una oficialidad que ellos —años de la clase dirigente. La lejanía de las campañas y la necesidad de soldados dedicados con exclusividad y el cambio fue realizado por Mario en

el año 103 a.C. ante grave invasión de tribus germánicas. La oficialidad siguió siendo como antes, pero el comando pasó, a partir de Sila, a los promagistrados o a los elegidos para un *imperium extraordinarium*. Los soldados profesionales sentían ligada su suerte a la de su jefe y lo apoyaban en los conflictos políticos. Se sumó así, en la vida de la *res publica*, a la corrupción, la violencia en gran escala.

• (C) Los pueblos latinos e itálicos aliados (*socii*) a Roma habían compartido la empresa imperial y aspiraban a compartir las ventajas y derechos de los ciudadanos romanos. Fracasados los planes de los Gracos y de Livio Druso (81 a.C.) para posibilitar tales aspiraciones, se desató la Guerra Social —llamada así por ser emprendida por los *socii* (los aliados, los que acompañan)—. Roma la aplacó, pero cedió políticamente: todos los hombres integrantes de las comunidades de la península, al sur de los ríos Arno y Esino, recibieron la ciudadanía romana. La ciudad estado resultaba crecida fuera de toda posibilidad de normal o auténtico funcionamiento de sus órganos: la asamblea de

ciudadanos, por ejemplo, en la práctica sólo se integraría con los avelinados en la urbe y sus alrededores.

- (D) Sila, vencedor, en verdadera guerra intestina, del caudillo popular Mario, se hizo nombrar dictador con poder constituyente (*res publica constituendae*). Procedió a una reorganización de la *res publica* anulando los anteriores avances democratizantes —por ejemplo, suprime la *intercessio*° (poder de veto) de los tribunos de la plebe, y reemplaza el proceso comicial ante el *populus* por tribunales permanentes de senatoriales— y consolidando el peso político del Senado, cuyo número de integrantes llevó a trescientos a seiscientos.

Su más trascendente y duradera reforma fue la reglamentación de la promagistratura: mientras los magistrados duraran en su cargo no podían ejercer el *imperium militiae* —fuera de Roma— sin encargo especial del Senado. El *imperium militiae* quedaba, entonces, sólo para (A) los ex cónsules y ex pretores, que pasaban ahora en forma sistemática a desempeñarse como promagistrados —procónsules y propretore— en las provincias, y (B) para aquellos políticos a los que los comicios les otorgaban los *imperia extraordinaria* sin límites de tiempo y, a veces, de espacio, como el *imperium infinitum* otorgado a Pompeyo para batir en toda la cuenca mediterránea a los piratas.

Pero precisamente la concesión de esos *imperia extraordinaria* —que las emergencias internas, como las sublevaciones de Lépido en la Galia Cisalpina, de Sertorio en España y de Espartaco al frente de esclavos, o los episodios bélicos externos hacían necesarios— otorgaba a sus titulares un tremendo poder militar, económico y aun electoral que iba a ir jaqueando al Senado y violentando cada vez más el funcionamiento, ya desfasado, de los órganos de la *res publica*.

GUERRAS CIVILES

En este período la violencia penetró sin tapujos en los conflictos políticos, que entraron a resolverse por las armas.

- Después de su victoria sobre la oligarquía senatorial y Pompeyo, César estableció un gobierno autocrático en su condición de dictador perpetuo y procedió a grandes reformas. Los intereses creados de la vieja clase dirigente y aun los auténticos y tradicionales ideales republicanos engendraron una reacción que puso fin a la vida de César y comienzo a una nueva guerra civil en la que la causa cesariana fue sostenida por la magistratura triunviral integrada por su principal colaborador Marco Antonio, por el aguerrido Lépido y por el joven Octavio, sobrino de César, que por adrogación° testamentaria de éste —confirmada por el comicio curiado— pasaba a ser su heredero civil y político.
- Vencidos los republicanos, el Imperio quedó dividido en la esfera occidental, confiada a Octavio —honrado con el epíteto de Augusto—, y la oriental, manejada por Marco Antonio en comunidad de planes con Cleopatra.

- El posterior conflicto entre ambos caudillos dejará un único vencedor, Augusto, que organizará con prudencia y astucia un nuevo sistema político: el Principado.

ORGANOS DE LA RES PUBLICA

La *res publica* se caracterizó por ser una estructura política basada en el equilibrado juego de tres órganos: la magistratura, el Senado y los comicios.

VER LÁMINA NÚMERO TRES.

LA MAGISTRATURA

Si bien originalmente había una sola magistratura, la creciente complejidad del aparato estatal fue haciendo necesaria la división en esferas de competencia y la consiguiente creación de nuevas magistraturas.

- Estas nuevas magistraturas continuaron con el *imperium*°, pero éste, por una concepción republicana del estado —más propensa a reconocer derechos individuales— y la voluntad popular, no conserva el carácter absoluto que había tenido en un principio.
- Este poder, conocido en el ámbito de la ciudad como *imperium domi* y en el campo militar como *imperium militiae*, era restringido en el primer caso por la *lex Valeria de provocazione* (300 a.C.), que reglaba la *provocatio*° *ad populum*, y en el segundo por la *lex Porcia* (principios del siglo II a.C.).
- El *imperium* abarcaba:
 - 1) el *ius agendi cum populo* —derecho a convocar y proponer leyes y candidatos a los comicios;
 - 2) el *ius agendi cum patribus* —para convocar al senado y someterle consultas;
 - 3) el *ius edicendi* —que lo facultaba a publicar edictos;
 - 4) jurisdicción —muy amplia, que no conocía diferencias entre asuntos penales, civiles o administrativos;
 - 5) la coercición —facultad para imponer penas de flagelación, confiscación o muerte en los casos de desobediencia a lo ordenado por el magistrado;
 - 6) mando militar —con las atribuciones derivadas de éste, tales como la distribución del botín, reglamentación y administración de territorios, etcétera;
 - 7) los auspicios, es decir el derecho de consultar a la divinidad e interpretar su respuesta.

Características de la magistratura romana. — (A) *Electividad*. Producto de la creciente importancia dada a la voluntad y soberanía popular. En un principio el magistrado designaba a su sucesor. Los magistrados mayores eran elegidos por los comicios centuriados, los menores por los comicios tribados y el tribuno y edil plebeyo por los comicios de la plebe. La excepción era el dictador, que era elegido por uno de los cónsules. Esta magistratura también resultó, posteriormente, electiva, cuando ya estaba en decadencia.

(B) *Gratuidad*. La magistratura era un honor, una carga pública. La gratuidad excluía de hecho a los ciudadanos pobres del ejercicio de las magistraturas.

(C) *Colegialidad*. Con la particularidad de que cada magistrado ejercía individual y autónomamente la totalidad del poder de la magistratura, pero en caso de disenso cualquier colega ejerce el veto (*intercessio*). Este sistema permitía la celeridad en la gestión, propia del magistrado único, con el control propio de los órganos colegiados.

(D) *Responsabilidad*. Al terminar la gestión el magistrado debía responder moral y jurídicamente por sus acciones. En la época de crisis de la *res publica*, la *abrogatio** implicó un principio demasiado revolucionario para la época: el del mandato popular, según el cual el magistrado sería responsable ante el comicio que lo había elegido y, en caso de mala gestión, podría ser destituido por éste.

(E) *Anualidad*. Los magistrados duraban un año en su gestión. Dado que este plazo, con la expansión romana, podía resultar muy breve, se recurrió a la ficción de la promagistratura, según la cual el ex magistrado, acabadas sus funciones, pasaba a actuar en lugar de, haciendo las veces de (*pro-*) magistrado. Las excepciones a la anualidad son el dictador, que duraba 6 meses como máximo, y el censor, que, elegido cada 5 años, duraba 1 año y medio en sus funciones.

Clasificación de las magistraturas. — I. Mayores y menores, según la facultad que tenían para consultar los auspicios. Son mayores: la dictadura, la censura, el consulado y la pretura; son menores la cuestura y el edilato.

II. Son ordinarias aquellas cuya elección está prevista regularmente (cada año y cada cinco años para la censura) y son extraordinarias aquellas que funcionan en circunstancias excepcionales, tal como la dictadura y el llamado Segundo Triunvirato.

III. Son del pueblo romano las que surgen de la elección de la ciudadanía toda, en los comicios centuriados o tribados. Las de la plebe son privativas de la plebe, puesto que habían nacido para su reivindicación y defensa, y surgen de los *concilia plebis*: tales, el tribunado y el edilato plebeyo.

IV. Son curules aquellas que tienen, entre sus atributos de poder, el uso de la silla curul: todas las magistraturas mayores y el edilato curul.

V. *Cum imperio*: dictador, cónsul y pretor; *sine imperio*: todas las otras.

Cursus honorum. — Sistema por medio del cual se regula el acceso y ascenso a las distintas magistraturas.

Con el tiempo se fueron conformando las normas y requisitos siguientes.

(A) La prohibición de desempeñar dos magistraturas ordinarias a un mismo tiempo; se podía, en cambio, una ordinaria y otra extraordinaria.

(B) Un intervalo de 10 años para asumir nuevamente una misma magistratura; posteriormente se prohibió la reelección para la censura (265 a.C.) y para el consulado (151 a.C.).

(C) Un lapso de 2 años como mínimo entre el ejercicio de dos magistraturas curules.

(D) Una edad mínima de 27 años para aspirar a cualquier magistratura.

(E) Una especie de "escalafón" de las magistraturas; por ejemplo, la cuestura se debía desempeñar antes que la pretura; ésta, antes que el consulado, al que debían seguir la dictadura o la censura.

DISTINTAS MAGISTRATURAS

El dictador. — Probablemente sucesor de lo que fue, en una época, el *magister populi*, cuyo *imperium*, en lo militar, se asemejaba al del *rex*.

Es instituido para ciertas circunstancias excepcionales y mientras duren ellas; de ahí que su *imperium** es militar, sin jurisdicción civil. En un comienzo era elegido por uno de los cónsules, a propuesta del Senado; como ya dijimos antes, adquirió posteriormente carácter electivo.

El cónsul. — La más alta magistratura ordinaria *cum imperio*. Se caracteriza por la *creatio* de magistraturas ordinarias —acto por el cual instituye al magistrado elegido por el correspondiente comicio.

El pretor. — Surge como colega menor de los cónsules en el año 367. Agregado en el año 242 a.C. el pretor peregrino, el número de pretores llega a aumentar hasta 16 bajo Julio César. No es un magistrado colegiado propiamente dicho, porque tiene competencia propia. Conserva el *imperium militiae*, en ausencia del cónsul.

El censor. — Magistrado mayor, *curul* y *sine imperio*. Se elegían dos censores por medio de los comicios centuriados. La censura patricio-plebeya comienza en el 340, con la costumbre de elegir a ex cónsules.

Entre sus funciones estaba: la confección del censo y de la *lectio senatus* (lista del Senado), el cuidado de las costumbres y las grandes contrataciones públicas.

El tribuno de la plebe. — Surgido como consecuencia de las luchas entre patricios y plebeyos, al integrarse estos últimos pasa a ser magistrado de la *civitas* y se convierte en órgano de control de las prácticas constitucionales. Con los Gracos comienza a reprimarse su antiguo carácter popular.

El edil. — Podía ser de dos clases: plebeyos y *curul*. Sus funciones eran la vigilancia y aprovisionamiento de los mercados (*cura annonae*), el cuidado y mantenimiento de la ciudad (*cura urbis*) y el control y ejecución de los juegos públicos (*cura ludorum*).

El cuestor. — Apareció vinculado con la represión criminal. Pasó a convertirse en auxiliar de los cónsules en el cuidado de erario, administración del ejército y en la instrucción de los procesos capitales, así como en la imposición de multas.

EL SENADO

Era el órgano de mayor importancia en la *res publica*. Diversos factores se conjugaron para hacer que el Senado sobresaliera: (A) era el único cuerpo estable y permanente que sesionaba sin solución de continuidad, con la consecuente experiencia y prestigio; (B) únicamente el Senado podía concebir estrategias y políticas de defensa y conquista por las razones ya mencionadas; (C) la experiencia y veteranía de sus miembros, en su mayoría ex magistrados y pertenecientes a las más prestigiosas familias romanas.

Composición. — El número fluctuó según los azares de la política romana. Fueron 300 hasta Sila, que lo llevó a 600; César aumentó el número a 900, pasando a ser 1.000 bajo el Triunvirato. Durante el Principado el número se niveló en 600.

* La *lex Ovinia* del 312 confirió la *lectio Senatus* a los censores y estableció un orden de prelación en la lista: primero se integraba con los senadores supervivientes del período anterior, siempre que no hubieran sido objeto de una *infamia censoria*; luego los ex dictadores, ex cónsules y ex pretores; posteriormente ex ediles, ex tribunos, ex cuestores y, por último, los ciudadanos con méritos especiales.

Funcionamiento. — El Senado tenía amplias posibilidades para su funcionamiento: aunque debía ser convocado por un magistrado con el *ius agendi cum senatu*, nada obstaba para su autoconvocación. A pesar de que tradicionalmente se reunía en un edificio llamado Curia, lo podía hacer en cualquier sitio y fecha, aun en días nefastos y sin tener que consultar los auspicios. Tampoco tenía quórum, funcionando con el número de senadores que se hallaren presentes.

* El derecho de voz y voto no estaba sujeto a ningún impedimento, aunque consuetudinariamente se estableció que primero hablara el *Princeps* (primera cabeza) del Senado, el más antiguo ex censor, haciéndolo después los ex censores, ex dictadores, ex cónsules, etcétera. Dado el número de senadores, era común que los de las últimas categorías no llegaran a hacer uso de la palabra, adquiriendo el mote de *pedarii* —de *pedes* (pie)— porque lo único que podían hacer era desplazarse hacia donde se encontraban los que sustentaban su misma posición en la materia que se trataba, pues ésta era la forma en que se votaba.

Atribuciones. — De acuerdo con la tradición constitucional son (A) la provisión de un *interrex*; (B) la *auctoritas patrum* y (C) el *consultum*. Pero, en la práctica, no hubo límites para la ingerencia del Senado en la deliberación, ejecución y administración de los intereses públicos: relaciones exteriores, finanzas, política monetaria y del *ager publicus**, control sobre cultos y sobre la administración provincial, etcétera.

* La provisión de un *interrex*. La misma institución —y la misma terminología— que había servido para la eventualidad de que el *rex* hubiera muerto sin designar sucesor: el Senado elegía uno de sus miembros para que cumpliera durante cinco días con las funciones de *rex* y designara o bien otro *interrex* (rey interino), o, si los auspicios se lo indicaban, al *rex* definitivo. Claro que en la época republicana se sucedían los *interreges* cada cinco días hasta que podía reunirse el comicio centuriado en que se elegiría a quienes tomarían el lugar de los faltantes cónsules.

* *Auctoritas patrum*. *Auctoritas** es un vocablo muy usado y con amplia gama de acepciones. Derivado de la raíz *aug* (aumentar, tener auge) tiene un valor genérico y primario de un poder de naturaleza tuteladora con que se aumenta o incrementa un deficitario poder o capacidad. *Auctoritas patrum* era, pues, el incremento de poder con que los *patres**, designación primera de los senadores, completaban la decisión de las asambleas populares. El avance del concepto de soberanía popular habría de suprimir ese requisito para la validez de los pronunciamientos comiciales.

* *Consultum*. La función esencial y normal del Senado era deliberar acerca de cuestiones planteadas en consulta por los magistrados y votar la consecuente respuesta (*senadoconsultum**).

LOS COMICIOS

Contrariamente a lo que ocurría en las otras ciudades estados en las que existía una asamblea popular, el ya comentado sentido conservador de los romanos les hizo hacer coexistir hasta cuatro tipos de reunión (*comitium*) de la ciudadanía, originados en distintas circunstancias y con distintos presupuestos y finalidades.

* El comicio curiado, basado todavía en la organización gentilicia, sólo tendrá en la *res publica*, fuera de la formalidad de solemnizar el reco-

nocimiento de los magistrados *cum imperio* (*lex curiata de imperio*), funciones de control de actos vinculados con la organización familiar.

* El comicio centuriado, verdadera expresión del *populus* en su versión timocrática, seguirá siendo el más importante (*comitatus maximus*) y necesario para las más trascendentes manifestaciones de la soberanía popular.

* El concilio de la plebe, asamblea revolucionaria en sus orígenes, se había legitimado e integrado a la *ciuitas*. Cuando se llega a la equiparación de los plebiscitos con las *leges* el concilio resulta el más ágil y frecuentado medio de legislación pública. Después de los Gracos será el escenario de las agudas luchas políticas.

* El comicio tribado, organizado sobre la misma base del concilio de la plebe —la distribución de la ciudadanía según la ubicación de sus fundos en las tribus territoriales— se confunde a veces con éste, aunque teóricamente se diferencia (A) en que se integra también con los patricios, (B) en que debe ser convocado por magistrados del pueblo y no de la plebe.

Atribuciones. — Los tres últimos tipos de asamblea popular suelen tener promiscuamente atribuciones legislativas, electorales y judiciales, aunque haya especificidad o graduación en cuanto a qué magistrados elige o qué clase de juicio penal resuelve cada asamblea.

Funcionamiento. — Es conveniente destacar los siguientes pasos, requisitos y modalidades: (A) debían ser convocados con, por lo menos, 24 días de anticipación; (B) en ese intervalo se publicaban proyectos y candidaturas y tenían lugar encuentros (*contiones*) informativos en que los magistrados y ciudadanos podían opinar; (C) la noche antes del comicio el magistrado debía consultar los auspicios; (D) si eran favorables tenía lugar el comicio, en el que el magistrado exponía su proyecto legislativo o los candidatos; (E) ante la pregunta (*rogatio*) del magistrado, la ciudadanía emitía su voto —que llegó a ser secreto—, siempre dentro de su unidad —curia, centuria o tribu—; (F) definido el sentido de la votación en cada unidad votante, se hacía el escrutinio de las unidades definidas en un sentido o en otro —un resultado sería, por ejemplo, en un comicio centuriado, 100 centurias por la aprobación de una *rogatio* y 93 por el rechazo; en un tribado o en un concilio de la plebe, 20 tribus en un sentido y 15 en el otro—; (G) el magistrado podía interrumpir el acto, establecer que se comenzara de nuevo y hasta no aceptar el resultado.

ESTRUCTURACION DEL ÁMBITO HEGEMÓNICO ROMANO DURANTE LA RES PUBLICA

La expansión, al principio espontánea y luego consciente y hasta planificada, de la hegemonía romana estructuró un complejo sistema de sujeciones y alianzas centrado en la supremacía (*maiestas*) de la *res publica romana*.

Los romanos no aplicaron criterios sistemáticos, o a priori, de organización del ámbito en que se desplegaba el *imperium* de sus magistrados o promagistrados: circunstancias históricas, diferencias culturales, limitación territorial de la ciudad estado, economía de recursos humanos, etcétera, fueron factores de una extrema variación y graduación de los status en que quedaron los pueblos dominados.

Sin embargo podemos sistematizarlos según dos pares de criterios: el del sistema de vinculación —federación o anexión— y el de la ubicación —dentro o fuera de la península itálica.

VER LÁMINA DOBLE NÚMERO CUATRO Y CINCO.

HEGEMONIA EN ITALIA

Anexión. — La *civitas* incorpora territorios y comunidades como propios a través de: (A) incrementar las tribus territoriales —hasta cuatro urbanas y treinta y una rústicas en el 241 a.C.—, (B) establecer colonias de ciudadanos romanos en lugares estratégicos de la península.

- Los territorios incorporados pasan a ser *ager romanus*.
- Las comunidades reciben la ciudadanía romana, sea plena (*optimo iure*), sea sin derechos políticos (*sine suffragio*), y mantienen una cierta independencia administrativa que les da el carácter de entes para-estatales con respecto a la *res publica*: se trata de municipios y colonias.

Los municipios conservan, en general, de su primitiva soberanía de ciudad estado, una administración autónoma en todo lo interno o local.

- La *iurisdictio* sobre los integrantes de los municipios corresponde, en principio, a los pretores, aunque subsistan para los *optimo iure* algunos de sus primitivos tribunales y para los *sine suffragio* el pretor delega su *iurisdictio* en los *praefecti iure dicundo* (encargados de declarar el derecho) elegidos por él y más adelante por los comicios.

- A partir de la *lex Iulia municipalis* de Julio César (44 a.C.) habrá para los municipios una uniforme estructura de gobierno, calcada de la de Roma: dos magistrados jurisdiccionales (*duo viri iure dicundo*), dos ediles, un senado vecinal de cien decuriones y una asamblea de diez curias.

Las colonias romanas fueron incrustaciones de comunidades de ciudadanos romanos en territorios de interés estratégico.

- Esos ciudadanos seguían inscriptos en las tribus de la metrópolis, pero, por razones de distancia, sólo podían participar en el gobierno local de la colonia.
- Al principio las razones para establecer colonias fueron militares, pero luego sirvieron para proporcionar tierras a los proletarios o a los soldados veteranos.

Federación. — Las viejas prácticas de alianzas entre pueblos o ciudades estados se convirtieron en el recurso principal de Roma para institucionalizar su influencia y hegemonía.

- Roma fue el centro de una compleja red de lazos federativos de *civitates* con territorio, ciudadanía y gobierno propios, pero que eran *socii* (socios, seguidores) pues debían acompañar, seguir, a Roma en la política exterior.
- Los *socii latini*, al principio definidos étnicamente pero después engrosados por comunidades no latinas pero a las que Roma concedía condición latina, tenían una situación de alianza privilegiada y un camino abierto a la obtención de la ciudadanía romana.

HEGEMONIA FUERA DE ITALIA

Anexión. — El grueso del ámbito hegemónico lo constituían las llamadas *provinciae*, compuestas por comunidades cuyo territorio había devenido *ager publicus* * y cuyos integrantes eran considerados peregrinos.

- *Provincia* —palabra cuya raíz es *vincire* (sujetar)— designaba el ámbito sujeto, sometido, al *imperium* de un magistrado o promagistrado. De allí que, por extensión, se llamara *imperium* al conjunto de pueblos sometidos a la hegemonía romana.

Sila organizó el sistema por el cual los cónsules y los pretores, terminado el año de su magistratura, pasaban a desempeñarse como promagistrados * al frente de las provincias, según una distribución en la que tenía intervención el Senado.



- * Este también es *provincia*, de entre sus miembros, a legados que lo acompañaran en su labor de gobierno.
- * El procónsul o el pretor al frente de una provincia tiene (A) el mando de todas las fuerzas militares; (B) la administración civil y (C) la jurisdicción, tanto en lo penal público como en las controversias privadas.
- * A su jurisdicción penal pública están sujetos, en principio y en último grado, todos los que viven en la provincia, peregrinos y ciudadanos romanos.
- * En derecho privado su competencia está limitada por la subsistencia de los tribunales locales y el derecho que aplica es (A), entre ciudadanos, el romano, (B) entre peregrinos de la misma *civitas*, el ordenamiento local y (C) entre ciudadanos romanos y peregrinos y entre peregrinos de distintas *civitates*, las soluciones del *ius gentium* que se consignan en su edicto.

Sistema de alianzas. — Está integrado por (A) los *socii exterarum terrarum* (los compañeros de tierras exteriores [a Italia]) que, aunque incluidos en las provincias, gozaban de un régimen similar al de las *civitates* itálicas; (B) los protectorados o ciudades estados y reinos satélites, los que terminaron por ser sometidos al sistema provincial.

A CONDICION DEL SUELO

Para comprender el sistema imperial y el contenido de algunos derechos privados reales romanos es necesario tener algún concepto de lo que fue el *ager publicus* (tierra pública).

Ager romanus. — Es el territorio comprendido en los límites de la ciudad estado Roma, ensanchados paulatinamente, como se ha visto, por el mecanismo de la anexión en Italia. Sólo en él el ciudadano romano podía ser titular, en un *ager privatus*, de *dominium * ex iure quiritium* (propiedad de acuerdo al derecho quirítico), caracterizado por su absoluté e inmunidad —no sujeta a carga o tributación.

I. Tal vez desde el siglo III a.C. y, sin duda, desde la ampliación de la ciudad estado consecuente a la Guerra Social, toda la península itálica fue asimilada a esa particular condición de poder ser objeto del *dominium * ex iure quiritium*. Por eso los textos hablan de que sólo los fundos itálicos son *res mancipi **

es decir, cosas sujetas al *mancipium ** y, por lo tanto, sólo transferibles por una *mancipatio **.

II. Esa condición se extendió luego, excepcional y limitadamente, a zonas extraitálicas, privilegiadas así con el llamado *ius italicum* (condición itálica).

III. En el resto del ámbito hegemónico no fue posible —en teoría hasta Justiniano— ser titular de *dominium*. Salvo algunos territorios sujetos a propiedad privada peregrina, si totalidad del suelo provincial era *ager publicus*.

Ager publicus. — Es el suelo sobre el que el *populus*, en su significado de estado, ha adquirido por el hecho de la conquista un derecho de dominio eminente que, si bien puede dar lugar a la concesión a particulares de variados derechos, excluye la posibilidad de un derecho pleno, absoluto, inmune como era el *dominium * ex iure quiritium*.

- * En el *ager romanus* hubo partes que eran *ager publicus* pero, a través de distintos regímenes, fueron deviniendo plena propiedad privada, con la principal excepción del *ager vectigalis*.

I. Es sumamente compleja la variación de regímenes jurídicos y de explotación económica que Roma aplicó al *ager publicus*; los más característicos e importantes son el del *ager occupatorius*, el del *ager viritanus*, el del *ager vectigalis*, el del *ager stipendarius* o *tributarius* o *decumanus*.

- * *Ager occupatorius* era el librado a la ocupación precaria de cualquier ciudadano romano, muy probablemente gratuita. Se trataba de tierras incultas que los particulares ocupantes no podían limitar con hitos ni cercos. Este régimen permitió de hecho la creación de grandes latifundios en manos de la clase senatorial, con medios económicos para su explotación. La reforma agraria de los Gracos se dirigió contra ese abuso. Desde el 111 a.C. pasó a ser propiedad privada.
- * *Ager viritanus* era el directamente asignado en propiedad a *viri* (varones) romanos.
- * *Ager vectigalis* era el situado en suelo itálico, dejado a particulares, en una especie de posesión o usufructo, revocable o perpetuo mediante un pago periódico —*vectigal* (lo que se aporta, contribuye).
- * *Ager stipendarius, tributarius* o *decumanus* eran variantes, asimilables al *ager vectigalis*, que se daban en las provincias. Se trataba generalmente de tierras dejadas a los mismos particulares que las habían tenido con anterioridad a la conquista romana y que pagaban al *populus*

romano prácticamente lo mismo que antes habían pagado al poder político entonces vigente.

II. Con respecto al régimen jurídico del *ager vectigalis* y las otras variantes asimilables —las más importantes y duraderas del *ager publicus*—, los primeros juristas romanos hablaron tanto de una especie de locación como de una especie de propiedad provincial. Generalmente lo designaban como *ius in agro vectigali* (derecho sobre un suelo sujeto al pago de un tributo) o simplemente *possessio*. Su protección fue la que dio origen a la de la posesión*.

De hecho, los titulares —salvo el caso de unas variantes revocables que fueron desapareciendo— podían explotar esas tierras sin restricciones —enajenarlas, arrendarlas, dejarlas en herencia, etcétera—, como si fueran propietarios.

III. Cuando Diocleciano en el 297 d.C. impuso tributo también a los fundos itálicos, hasta ese momento inmunes, desapareció la única diferencia práctica entre el *dominium* y el derecho de los particulares sobre esas variantes de *ager publicus*. Los distintos tipos de pago al estado se confundieron en una indistinta contribución territorial.

PRINCIPADO

I. Su sistema político aparece en un principio como un compromiso entre las tradicionales instituciones de la *res publica* y la realidad y necesidad de un poder autocrático, que las irá sometiendo a un vaciamiento de atribuciones y competencias que se transfieren a una incipiente, pero rápidamente desarrollada, burocracia enteramente dependiente del Príncipe.

Con el tiempo, las formas republicanas cederán el paso a una fisonomía desembozadamente monárquica y militarista del poder.

II. En el orden imperial, si bien al principio la ecuación es (A) ciudad estado Roma —en los límites territoriales de la península itálica— como dominadora y rectora del (B) territorio provincial, la tendencia unificadora del Príncipe, de la burocracia

cia y del ejército llevó a esta otra ecuación: (A) poder imperial y burocrático gobernando a (B) todas las regiones y pueblos del Imperio con status equiparados, sobre todo, por la masiva extensión de la ciudadanía establecida por el Edicto de Caracalla en el año 212 d.C.

III. El establecimiento del Principado y las condiciones de orden y seguridad que proporcionó dieron lugar al llamado siglo de Augusto y a la *Pax Romana*, de casi dos siglos de duración. Pero luego de la dinastía militarista de los Severos se iniciará la gran anarquía militar, aguda etapa de la llamada crisis del siglo III.

EL SISTEMA POLITICO DEL PRINCIPADO

LOS PODERES DEL PRINCIPE

Augusto no tuvo una designación única —como la que tiene un rey o un presidente— que implicara una suma de poderes: su poder se fue componiendo con potestades, atribuciones y misiones que se le fueron concediendo sucesivamente. Todas ellas tenían un origen republicano: lo no republicano fue la concentración de todas ellas en una sola persona. Los poderes más importantes fueron el *imperium proconsulare maius et infinitum* y la potestad tribunicia.

* Su *imperium* no tenía límites temporales ni se constreñía a una provincia: le permitía el gobierno total de todas las provincias que le había encomendado el Senado, así como el mando y organización de las legiones en ellas establecidas.

* La potestad tribunicia le otorgaba la convocatoria del concilio de la plebe y del Senado, la inviolabilidad y el poder de veto, pero sin estar el sujeto al de los tribunos, ni al de ningún otro magistrado.

Aparte de muchas otras potestades —como la censoria, que le permitía confeccionar la lista de senadores—, cargos —como el de pontífice máximo—, prerrogativas —como el ser *Princeps Senatus* (primer integrante del Senado)— y títulos —como el de *imperator* (jefe militar victorioso)—, buena parte del poder de Augusto consistía en su *auctoritas** —prestigio gravitante en

todas las manifestaciones del estado y la comunidad— y en la amplia e indefinida *cura et tutela reipublicae* (cuidado y protección del estado) que le había encomendado el Senado.

Los cuidados, funciones y misiones que el Senado le iba confiando, hacían necesario que el Príncipe nombrara, de entre sus amigos y auxiliares, delegados o colaboradores que resultaron así los cabezas de un servicio administrativo o burocracia, que fue, poco a poco, sustituyendo a magistrados y promagistrados en el manejo de los intereses públicos.

La administración dejó, pues, de ser un *honor* ciudadano desempeñado anualmente y por elección popular, para ser una función permanente, atribuida y retribuida por el Príncipe.

Delegados del Príncipe fueron los distintos *praefecti, procuratores y curatores*.

LOS ORGANOS TRADICIONALES

I. El Senado, como institucionalización de la clase dirigente, ha perdido el poder, pero el Príncipe le reserva —tanto al cuerpo como a sus miembros— la alta administración imperial. Por lo demás, el Senado tomará las funciones legislativas de los comicios y elegirá a los magistrados.

II. Las magistraturas pierden la mayoría de sus atribuciones o competencias, aunque dan algún prestigio y, sobre todo, acceso al Senado. Y las promagistraturas desaparecen como necesaria prolongación —después de terminada la magistratura— del *imperium*.

III. Los comicios, convocados para reformas trascendentes por Augusto, dejaron pronto de serlo para la función legislativa y, a partir de Adriano, para la electoral.

NATURALEZA POLITICA DEL PRINCIPADO

Resultó, por lo menos en los primeros tiempos, una combinación muy original cuya definición ha dado lugar a distintos juicios.

* Mommsen, considerando que el territorio provincial se halla sometido a dos administraciones, la del Príncipe y la del Senado, habla de una *diarquía* (en griego: dos poderes soberanos). Pero si se observa la lámina número seis y se tiene en cuenta que, en virtud de su potestad censoria, el Príncipe es quien otorga la función senatorial, se debe coincidir en que el Príncipe controla al Senado y a sus delegados; pero que el Senado sólo gravita o influye en el Príncipe en la medida en que éste se sienta inclinado a ello, o que su poder o *auctoritas* esté muy deteriorado.

* Guarino llega a hablar de una democracia autoritaria, porque si bien el poder es autocrático y sin control institucional, cualquier ciudadano podía llegar a él —¿?— y aparecía, en última instancia, ejercido por delegación del *populus*.

* Lo que no puede discutirse es que se trata de un sistema *ad hominem* (para el hombre), es decir, a la medida de las circunstancias y atributos de Augusto, vencedor en una serie de agotadoras guerras civiles. La astucia del heredero de César disimuló su poder bajo el mantenimiento de las formas republicanas, pero sus sucesores fueron dejando traslucir el carácter autocrático del sistema.

* Con la dinastía de los Severos, la cruda realidad del sostén militar del régimen queda de manifiesto. Se pretende apuntalarlo con elementos mágico-religiosos del mundo oriental. Esa base carismática explica la tendencia dinástica, es decir, a fundar en el vínculo de sangre la legitimación del acceso al poder.

EVOLUCION ESTRUCTURAL DEL IMPERIO

Durante la *res publica* se había evolucionado desde una ciudad estado a un estado nación —Italia—, dominando imperialistamente sobre el territorio provincial y las ciudades estados federadas.

En el Principado se llegará a un estado universal, es decir, a una conformación unitaria del Imperio a través de cuatro procesos: (A) el de la transformación del vínculo de alianza o federación en el de anexión; (B) el de la equiparación, bajo el signo de la común dependencia del poder imperial y su consecuen-

te burocracia, entre el estado nación dominante y los territorios dominados; (C) el de la difusión de un mismo tipo de sistema municipal y (D) el de la extensión masiva de la ciudadanía a casi todos los hombres libres del Imperio.

- (A) Los protectorados se convierten en territorio provincial y las *civitates* extratállicas aliadas, transformadas generalmente en municipios, entran en la órbita del gobernador provincial. (Ver lámina número siete).
- (B) La ciudad estado Roma, devenida estado nación Italia, gobernada al principio por sus tradicionales órganos, fue quedando sometida a la administración de la burocracia imperial y del Senado e igualándose así las provincias uniformadas en dos categorías: las que dependían del Príncipe —las situadas en la periferia y por lo tanto con guarniciones militares— y las llamadas del pueblo romano, que son a su vez administradas por el Senado y sus delegados. (Ver lámina número ocho). Por lo demás, se ha visto ya que los fundos itálicos perderán su inmunidad, es decir, su condición de exentos de la tributación, con lo que desaparecerá toda diferencia real entre los suelos de las distintas regiones imperiales.
- (C) Un régimen municipal uniforme acabó de extenderse con el Edicto de Caracalla a todas las *civitates* peregrinas.
- (D) Los príncipes habían proseguido con la política de ir otorgando la ciudadanía romana individual y colectivamente a los grupos romanizados cultural o políticamente. La forma colectiva supone un paso previo, el de dar condición latina * (*ius latii*), que significa la automática ciudadanía romana para los que desempeñen honores en las magistraturas o curias. Pero Caracalla, en el año 212 d. C., de una vez, concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio con la excepción (A), tal vez, de los peregrinos dediticios*; (B) de los latinos junianos*; (C) de los libertos dediticios*; (D) de los bárbaros* federados y (E) de los ciudadanos que han perdido su condición por condena grave.

LOS GRANDES MOMENTOS HISTÓRICOS DEL PRINCIPADO

EL SIGLO DE AUGUSTO

La prudente política de Augusto, luego de los desastres e inseguridades de las guerras civiles, trajo tal orden, seguridad y prosperidad para todo el Imperio, que tradicionalmente se habla del siglo de Augusto como de un momento particularmente

PRINCIPADO

positivo y acompañado de un espléndido florecimiento artístico e intelectual.

- La administración de las provincias dejó de ser un régimen de explotación imperialista y de saqueo oligárquico: los gobernadores estuvieron celosamente vigilados por el poder central y se liberó a la economía provincial de las limitaciones impuestas en beneficio de Italia.
- Se procuró una vuelta a las tradicionales pautas morales y religiosas romanas, especialmente en el orden familiar y con el objeto de superar la crisis demográfica italiana.
- Se propugnó un restablecimiento de la clase de pequeños propietarios rurales, sobre todo a través del reparto de tierras a los veteranos.

PAX ROMANA

Así se denomina el excepcional momento en la historia universal en que una tan grande extensión —toda la cuenca del Mediterráneo— y por tanto tiempo —casi dos siglos— pudo vivir en paz y prosperidad.

- Fuera de las guerras de fronteras y de algunos localizados episodios violentos producidos por la falta de un mecanismo regular de acceso al poder imperial, hubo una seguridad y facilidades de comunicaciones que promovieron un gran intercambio comercial. Las ciudades conocieron un extraordinario esplendor tanto por el embellecimiento y confort urbanístico como por el nivel cultural de las élites del gobierno municipal.

LA CRISIS DEL SIGLO III

Pero a pesar de tantos aspectos positivos —y en ciertos casos, por causa de algunos de ellos—, una serie de factores negativos llevarán a la llamada crisis del siglo III.

- El talón de Aquiles del régimen augusteo era la no articulación de un mecanismo de acceso al poder. En la práctica, los príncipes elegían dentro de un ámbito familiar, o fuera de él, al hombre que les parecía más apto para la sucesión imperial: lo adoptaban como hijo —con lo que quedaba heredero del carisma y de enormes riquezas— y lo asociaban al ejercicio del poder de manera que, a la desaparición del Príncipe, fuera el personaje con más riendas de poder en las manos y pudiera así asegurarse el alto puesto vacante. Pero con el tiempo, este *modus operandi* fue dejando al descubierto la cruda realidad de que el soporte del poder era, en última instancia, la presencia, primero,

de la guardia pretoriana en Roma y, luego, de los grandes ejércitos fronterizos. Esto llevaría a las presiones militares sobre el Senado en cada episodio de sucesión imperial y, más tarde, a las sangrientas revueltas y abiertas guerras internas que se incluyen en la sugestiva denominación del medio siglo que va del 235 al 284 d. C.: la gran anarquía militar.

- La equiparación de status personales en el Imperio llevó a que la clase dirigente se integrara con elementos cada vez más alejados de las tradiciones culturales romanas.
- Nuevos grupos bárbaros se apretaban sobre las fronteras imperiales que ponían así un dique a lo que había sido un natural deambular de pueblos en etapa nómada tribal de cultura. La anarquía militar y la lucha contra el imperio persa posibilitaron la penetración de esos germanos dentro de las fronteras del Rin y del Danubio.
- En pleno esplendor de los centros urbanos se encontraban latentes causas de crisis económicas: la masa de riquezas, concentrada como resultado de las conquistas, se dedicaba a la promoción del consumo y no de la producción; las ciudades nuevas de la parte occidental eran parasitarias de las zonas campesinas, pues no tenían la actividad artesanal y comercial de los viejos centros urbanos de la parte greco-oriental del Imperio; el drenaje de oro y plata hacia los mercados del Lejano Oriente iría produciendo un enrarecimiento de los medios monetarios, al que se quiso solucionar con emisiones de inferior coeficiente metálico, con lo que sobrevinieron procesos inflacionarios y se llegó a prácticas de trueque, propias de una economía inferior.

EL DOMINADO

I. Luego de la gran anarquía militar de los años 235 a 284, el Imperio fue reorganizado, sobre todo por la incansable acción de Diocleciano y Constantino.

II. El poder político, fuertemente autocrático, acentuó su fundamentación teocrática tanto en la época pagana como en la cristiana.

III. El Imperio termina de configurarse como un estado universal, con la uniformidad de status de todas las comunidades y de los territorios.

IV. El cristianismo, perseguido por atentar contra la unidad y fortaleza espiritual del Imperio, resulta adoptado para, precisamente, proporcionársela.

V. El empeño por salvar al Imperio de sus peligros y falencias llevó a sus titulares, actuando a través de una ingen-

te y minuciosa burocracia, a tomar medidas cada vez más graves y rigurosas que configuraron un estado totalitario con un sistema agobiante de impuestos y prestaciones, con un paralizante intervencionismo económico y con una sociedad estereotipada en clases profesionales obligatorias y hereditarias.

VI. Las fuerzas militares, incrementadas pero siempre insuficientes, cada vez más serán integradas por los mismos bárbaros cuya entrada en el Imperio se quiere impedir.

VII. El Imperio, desde Diocleciano, es varias veces dividido para su mejor defensa o por compromisos políticos o dinásticos y otras tantas vuelve a unirse bajo un único emperador. Pero en el 395 se divide para siempre en dos partes, cada una de las cuales seguirá su destino: la oriental sobrevivirá en la forma cultural del Imperio Bizantino; la occidental sucumbirá a la penetración bárbara y a la debilidad de su economía y gobierno y terminará fragmentada en numerosos reinos bárbaros.

REORGANIZACION DEL IMPERIO

I. Basándose en el antiguo principio romano de que el magistrado crea al nuevo magistrado y en la práctica de los Príncipes de adoptar un heredero y compartir con él el poder, Diocleciano estructuró el sistema de la tetrarquía, con el doble fin de asegurar una más eficiente defensa de las fronteras y de articular un mecanismo regular de acceso al trono imperial.

- Dividió al Imperio en una parte oriental, que gobernó personalmente, y otra occidental, que confió a su compañero de armas, Maximino. Luego esos dos "Augustos" eligieron a un "César" cada uno y le adjudicaron una parte de sus respectivos territorios. Hubo, pues, cuatro cabezas imperiales: una tetrarquía. (Ver lámina núm. 8 ocho).
- A la muerte o retiro luego de veinte años de reinado, cada "Augusto" debía ser reemplazado automáticamente por el "César" correspondiente, que, a su vez, elegía otro "César". Esta solución, perfecta en la teoría, no funcionó en la práctica por el juego de ambiciones políticas.

II. Para evitar que el tradicional acoplamiento del poder militar con la administración civil favoreciera las intrigas y los pronunciamientos que habían llevado a las disputas y usurpa-

ciones del poder imperial, Diocleciano puso al frente de los ejércitos a *duces* (conductores) de extracción militar, sin nada que ver con el gobierno civil de las provincias.

III. El ejército, casi duplicado en sus efectivos, se estructuró en (A) guarniciones limítrofes, (B) un cuerpo móvil estratégico y (C) la guardia palaciega.

IV. La burocracia, también incrementada, fue centralizada al máximo.

V. En el plano económico, a una oportuna reforma monetaria se añadió el comienzo del intervencionismo estatal y de la fijación de las clases sociales en el quehacer profesional.

VI. Constantino, por su parte, al establecer en la antigua colonia griega de Bizancio la sede del gobierno imperial, Constantinopla (la *polis* de Constantino), y al disponer, para su muerte, un reparto dinástico del poder contribuyó a la futura definitiva división del Imperio.

VII. Siguiendo la tradición comenzada por Heliogábalo de reforzar el poder asociándolo a religiones populares, Constantino cambia totalmente la política hacia el cristianismo, al que adopta y pretende dirigir. Los cristianos, indiferentes antes y hasta hostiles ante el poder estatal, lo verán entonces como un instrumento divino para la evangelización de los pueblos.

VIII. Constantino acentúa el carácter oriental y carismático del poder y deja de lado toda tradición romana, como, por ejemplo, la distribución de los altos cargos burocráticos entre la clase senatorial y ecuestre: de ahí en adelante uno pertenecerá a la clase que corresponde a su puesto y no por su clase accederá a los puestos.

FISIONOMIA Y ORGANIZACION DEL PODER

Quien se halla al frente del poder es ahora un *Dominus* (dueño y señor), un personaje divinizado, una verdadera encarnación sacralizada del estado.

El es la única fuente de la ley, aunque —sobre todo por la

influencia cristiana— su poder debe enmarcarse en los principios del derecho natural, “siempre firmes e inmutables”.

La voluntad del *Dominus* sostiene, en forma explícita o implícita, toda decisión, todo accionar político, militar, judicial, legislativo, religioso, etcétera. No hay otra fuente originaria de poder que ésa, la que se canaliza a través de una ingente, omnipresente y sofisticadamente jerarquizada burocracia: todo funcionario es un delegado imperial.

Los antiguos órganos sobrevivientes —algunas magistraturas, el Senado de Roma y su similar de Constantinopla—, o conservan un valor formal —o de protocolo—, o tienen competencias estrechamente municipales.

ESTRUCTURA DEL IMPERIO

Diocleciano subdivide las provincias, que de 42 —época de Trajano— llegan a un centenar, todas dependientes, ahora, del *Dominus*. Pero las agrupa en diócesis —seis en Oriente y otras tantas en Occidente—, con vicarios a su frente.

Italia, en un plano de igualdad con el resto del Imperio, queda, sin embargo, con una subdivisión propia, siete circunscripciones, cada una con un *corrector*, y Roma y sus alrededores, con un *Praefectus urbi*. Constantinopla tiene también ese mismo régimen de excepción.

Más tarde, las provincias occidentales son agrupadas por Constantino en tres prefecturas y las orientales son administradas por un colegio de dos prefectos.

EL CRISTIANISMO Y EL IMPERIO

Los romanos, por ser politeístas, eran naturalmente tolerantes con todas las religiones y admitían con interés y fervor nuevas divinidades en su *Panteón* (todos los dioses). Sólo requerían, como prenda de unidad o lealtad, el culto al emperador y a Roma. Les había chocado la negativa de los judíos y cristia-

nos, que precisamente por ser monoteístas, no toleraban otros cultos.

De todos modos, durante los siglos I y II d.C. las persecuciones a los cristianos habían sido esporádicas y locales: sólo ante la presión de amplios sectores populares muy prejuiciados contra los cristianos, las autoridades los reprimían como culpables de prácticas e ideas sospechosas. No hubo legislación general en tal sentido y algunos emperadores se esforzaron por encauzar jurídicamente la cuestión y evitar abusos.

Pero en el siglo III y principios del IV la persecución se sistematizó por la acuciante y directa intervención del poder imperial, que consideraba un peligro para la unidad y seguridad del Imperio la actitud pacifista y la indiferencia de los cristianos para con el cumplimiento de deberes hacia el estado. Septimio Severo, a fines del siglo II, había prohibido las conversiones al cristianismo: desde el 250 d.C. y especialmente durante Diocleciano las persecuciones fueron dispuestas por edicto: obligación de culto imperial y de abjurar del cristianismo, pérdida de derechos, cárcel y torturas, destrucción de templos y libros, etcétera. Pero después del Edicto de tolerancia (311 d.C.) de Galerio —“César” del mismo Diocleciano, ya retirado— y del Edicto de Milán (313) proclamando la neutralidad del estado en materia religiosa, Constantino dio un giro completo: favoreció a los cristianos y convocó al primer concilio ecuménico, el de Nicea. Había comprendido que eran la única gran fuerza espiritual que podía apuntalar al Imperio.

CONCEPCION TOTALITARIA DEL ESTADO

El poder autocrático —sin límites ni frenos institucionalizados—, para dar solución a los cada vez más graves problemas y peligros del Imperio, fue configurando una política totalitaria como resultado de una abusiva e indiscriminada extensión del concepto de *publica utilitas* a todos los ámbitos y manifestaciones comunitarias.

Todo interés de particulares o de grupos, toda actividad eco-

nómica, toda condición social debía ceder a las exigencias del interés del estado, que imponía entonces regulaciones tanto más coactivas cuanto más ineficaces iban resultando en la práctica.

- Para mantener la pesada máquina burocrática y la militar los tributos habían ido creciendo sin pausa. Pero el mantenimiento de los servicios del estado fue exigiendo, además, numerosas y agobiantes prestaciones personales y patrimoniales, gratuitas y obligatorias, conocidas con el nombre de *munera*: por ejemplo, arreglar los caminos vecinos, cobrar los impuestos y responder de los déficit, estar sujeto a requisiciones, etcétera.
- Los aspectos críticos de la economía, arruinada desde la crisis militar del siglo III, motivaron políticas de desastroso y paralizante intervencionismo estatal, como el Edicto del Máximo —fijación de precios máximos de bienes y servicios— y las innumerables constituciones imperiales que, pretendiendo prever o conjurar escaseces de mano de obra, fueron configurando un sistema de castas profesionales —colonos, transportadores, artesanos, soldados, artistas del espectáculo y otros—, obligatorias y hereditarias en las que los individuos quedaban definitivamente atados a su función económica, considerada en la concepción autoritaria y totalitaria, un ineludible servicio público.

LOS BARBAROS Y EL EJERCITO

Desde el principio de nuestra era, pueblos bárbaros, generalmente de origen germánico, se arremolinaban junto al *limes* (límite), la frontera fortificada, pretendiendo entrar al Imperio. Para superar el déficit de vocaciones militares y de mano de obra rural, le pareció al poder imperial doblemente conveniente admitir a pueblos enteros de ellos para que se asentaran como agricultores con el compromiso de defender el *limes* de la penetración de sus congéneres. También se reclutaron bárbaros para el ingreso individual en los continentes militares.

- La paulatina “barbarización” del ejército se hallaba, no obstante, moderada por el hecho de que los comandantes y alta oficialidad eran hombres de la clase senatorial y ecuestres, volcados a un servicio unitariamente administrativo y militar.
- Pero cuando Diocleciano dividió el servicio civil (*militia palatina*) del ejército (*militia armata*), los cuadros de comando quedaron abiertos para los soldados de carrera, que eran, en su gran mayoría, bárbaros. El poder militar llegó a quedar entonces en manos de jefes como Estilicón, Aecio y Ricimír que, por su origen bárbaro, no osaron ocupar el trono, pero pusieron y sacaron emperadores.

15

DIVISION DEL IMPERIO

Durante la anarquía militar del siglo III el Imperio había quedado dividido de hecho en varias partes sujetas al poder de distintos aspirantes al trono imperial. Con el sistema de la tetrarquía por primera vez se hizo una división de derecho. Se sucedieron, según los avatares políticos y dinásticos, reunificaciones y divisiones, hasta que a partir del 395 la partición hecha por Teodosio el Grande —confiando a sus hijos Arcadio la parte oriental y Honorio la occidental— resultó definitiva. Se acentuaron las existentes diferencias culturales y económicas, y aunque se mantuvo, incluso con relevancia en el ordenamiento jurídico, la teórica unidad imperial, en la práctica se fue esfumando la solidaridad entre ambas regiones.

- El poder imperial en la parte oriental, gracias a su mayor solidez económica, pudo mantenerse frente a las grandes invasiones y a las tendencias feudalizantes de los grandes latifundistas.
- En cambio, en la parte occidental no fue posible atajar la irrupción de nuevos pueblos bárbaros ni evitar que el poder militar en manos de los pueblos bárbaros federados como aliados encargados de la defensa convirtieran al poder imperial en una ficción que acabó de desvanecerse en el año 476, cuando Rómulo Augusto fue sacado del trono y las insignias del poder fueron enviadas a Zenón, emperador en Oriente, que se guardó muy bien de querer intervenir en la parte occidental.

Los jefes bárbaros y sus pueblos quedaron como clase dirigente en las distintas regiones de esa parte occidental, que quedó, así, fragmentada en reinos germánicos de variantes fronteras.

CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO ROMANO

CONCEPTO DE FUENTES DEL DERECHO

Llamaremos fuentes del derecho a los modos institucionalizados por los que la norma jurídica se objetiva, se explicita como tal, ante los miembros de la comunidad.

Esos miembros tienen la sensación o convencimiento de que existe un criterio normativo, una regla obligatoria de conducta más o menos sostenida por la amenaza de una sanción directa o indirecta, que puede oscilar desde un quitarle validez o eficacia a lo actuado con desconocimiento de ese criterio, hasta un infligir un castigo por un accionar prohibido.

En general, y según los momentos culturales, lo que la norma expresa se hace patente en una determinada comunidad a través (A) de la constatación de ciertos modos estereotipados de conducta que parecen responder a una directiva o regla implícita, o (B) de la prédica de ciertos individuos calificados por su saber jurídico, o (C) de las declaraciones o sentencias sobre casos concretos por parte de quienes tienen la función de administrar justicia, o (D) de preceptos emanados, en abstracto, de órganos públicos específicamente habilitados o reconocidos para esa función normativa. Es decir que, como generalmente se enseña, fuentes del derecho son (A) la costumbre, (B) la doctrina, (C) la jurisprudencia y (D) la ley, respectivamente.

LA COSTUMBRE

La costumbre es un hábito jurídico practicado desde un cierto tiempo en forma regular, constante, pública y pacífica en un determinado grupo social, con espontaneidad —es decir sin la imposición de una autoridad política o de una obligación legal— y con la general convicción de su valor normativo.

DOCTRINA

Doctrina es el conjunto de la elaboración intelectual de los juristas, sobre el *ius conditum* (el derecho establecido) y *ius condendum* (el derecho que debe establecerse).

JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia —en el sentido actual, no en el romano, que equivale, en todo caso, al de doctrina— es la interpretación y desarrollo del plexo jurídico por órganos que tienen la función de juzgar.

LEY

Por ley entendemos, en general, toda preceptiva expresada conceptualmente y emanada de los órganos a los que la estructura jurídica de la comunidad tiene asignada esa función normativa: parlamento, consejo, magistrado, comicio, etcétera.

Las dos últimas fuentes son autoritarias en tanto la norma resulta de la actividad de órganos estatales con específica competencia derivada del ordenamiento o del poder político. Las dos primeras, en cambio, son fuentes no autoritarias porque la norma deviene de un juego de hechos o conductas —costumbre— o actividades intelectuales —doctrina— de individuos que obran en forma particular, es decir, sin investir ningún cargo o misión derivado de la autoridad o poder político.

Los romanos, en lugar de usar nuestra metáfora de “fuentes del derecho”, consideraban más bien a la costumbre, la doctrina, la ley, etcétera, como partes constitutivas del ordenamiento jurídico. Así se puede ver en la traducción que se transcribe del comienzo del manual por el que estudiaron los jóvenes del Imperio Romano a través de más de tres siglos, las *Institutiones* o *Instituta* de Gayo.

I. Todo pueblo regido por leyes y por costumbres se vale, en parte, de un derecho que le es propio y, en parte, de un derecho que le es común con el conjunto del género humano. En efecto, el derecho que se da a cada pueblo, ese derecho propio, se llama derecho civil, como que es propio de la ciudad.

En cambio, el que entre todos los hombres establece la razón natural, ése se observa por igual entre todos los hombres y se llama derecho de gentes, puesto que de él se valen todas las gentes. Así, pues, el pueblo romano se rige en parte por un derecho propio, en parte por un derecho común a todos los hombres. En su oportunidad señalaremos cuál es el uno y cuál es el otro.

II. El derecho propio del pueblo romano se compone de leyes, de plebiscitos, de senadoconsultos, de constituciones de los emperadores, de los edictos de quienes tienen facultad de producir edictos, y de las respuestas de los prudentes.

III. Ley es lo que el pueblo manda y establece. Plebiscito es lo que la plebe manda y establece. La plebe se diferencia del pueblo en que con el nombre de pueblo se indican todos los ciudadanos, comprendidos también los patricios, y por plebe se entiende el conjunto de ciudadanos con exclusión de los patricios. De allí que antes los patricios sostenían que ellos no estaban obligados por plebiscitos, puesto que eran hechos sin su intervención. Pero, con posterioridad, se dictó la ley Hortensia por la que se estableció que los plebiscitos tendrían vigencia para todo el pueblo. Así, de esa manera, fueron igualados a las leyes.

IV. Senadoconsulto es lo que el Senado manda y establece; tiene fuerza de ley, aunque esto último haya sido cuestionado.

V. Constitución del emperador es lo que éste ha decidido por decreto o por epístola. Nunca se ha dudado de que tenga fuerza de ley, puesto que el mismo emperador recibe su poder en virtud de una ley.

VI. Los magistrados del pueblo romano tienen el derecho de producir edictos, pero el derecho de más amplio campo de aplicación se encuentra en los edictos de los pretores: el urbano y el peregrino, cuya jurisdicción tienen los gobernadores en las provincias a su cargo.

También en los edictos de los ediles curules, cuya jurisdicción tienen los cuestores de las provincias del pueblo romano, pues en las provincias del César no se envían, por cierto, cuestores y por lo tanto no existe en las provincias este edicto.

VII. Las respuestas de los prudentes son las sentencias y opiniones de aquellos a quienes se les ha acordado establecer el derecho. Si las opiniones de todos éstos coinciden, aquello que opinan obtiene fuerza de ley; si, en cambio, disienten, resulta lícito para el juez seguir la opinión que le parezca; esto es lo que se indica en un rescripto del divino Adriano.

DERECHO ARCAICO

CARACTERES DEL DERECHO ARCAICO

Algunas de sus características son más o menos comunes a todos los ordenamientos jurídicos primitivos —(A), (B) y (C)—; las otras son propias de los primeros tiempos del Derecho Romano —(D), (E)— o lo caracterizan a lo largo de casi todo su desarrollo —(F), (G), (H).

(A) CONSERVATISMO

El sentido tradicionalista, la tendencia a la conservación de sus instituciones, se da en Roma, paradójicamente, con una flexible disposición a estar continuamente adaptándolas a los cambios sociales y económicos o a crear otras al margen de aquéllas, pero sin derogarlas, ni suprimirlas de golpe, ni por completo.

(B) PREPONDERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE PODER Y DE STATUS PERSONAL

El ordenamiento primitivo romano presenta una sociedad con base en grupos familiares "políticamente" estructurados alrededor del poder del *paterfamilias* y con sólo una rudimentaria técnica de lo que para nosotros son los regímenes de intercambio de servicios y bienes y de apropiación de estos últimos.

(C) SENTIDO EXCLUSIVISTA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO

Que la clase patricia creara y usara para sí su ordenamiento se explica por el sentir —como en todos los pueblos antiguos— de que sólo los integrantes de una comunidad podían usar de sus instituciones. Producida la integración patricio-plebeya, el *ius civile* será exclusivo —como su nombre lo indica— de los *cives*, es decir de los ciudadanos romanos. No es sino el principio de la personalidad * de las leyes.

(D) ORIGINALIDAD

No se ha podido identificar en el ordenamiento arcaico romano influencias o aportes de otros derechos antiguos. Aun comparándolo con instituciones paralelas de otros pueblos indoeuropeos de su misma época o nivel cultural, el romano se destaca por su mayor arcaísmo y rigidez, y, sobre todo, por la persistencia de un fuerte y vitalicio poder unitario del *paterfamilias*.

(E) DINAMISMO

La voluntad divina, asociada con los ordenamientos primitivos, no se cristalizó en algún conjunto de "mandamientos" como en el Viejo Testamento, sino que se expresó —en cada caso concreto presentado a decisión— por intermedio del *rex* y los *pontifices*.

Fue posible, así, en lugar de la inalterabilidad de lo sagrado, una dinámica y plástica adecuación a las exigencias de la evolución cultural.

(F) TEMPRANO DESLINDE ENTRE LO JURIDICO Y LO MAGICO RELIGIOSO

Esa atribución de las normas a la voluntad divina, el papel de los sacerdotes en la interpretación y aplicación del derecho,

la promiscuidad de supersticiones, ritos mágicos, preceptos morales y sanciones religiosas entre disposiciones de índole jurídica son clara manifestación de que en el pensamiento primitivo había una indiferenciación o confusión entre preceptos que hoy distinguimos como mágicos, religiosos, morales o jurídicos. Pero es fácil observar en Roma, desde los comienzos, y marcando en esto una profunda diferencia con todas las otras comunidades, una decidida tendencia a desglosar lo jurídico de lo extrajurídico. La consideración laica, podríamos decir, del derecho llevó a que, sin el temor reverencial a lo vinculado con el pensamiento mágico religioso, aquél fuera tratado con criterio funcional, pragmático, como una técnica de regulación de relaciones humanas.

(G) FORMALISMO

Sin embargo, persistió en el ordenamiento arcaico romano la influencia de las ideas mágicas y religiosas que daban a los gestos, símbolos, ficciones, palabras, una significación, una fuerza en sí mismos, o, por lo menos, una relación simpática o íntima con las cosas, poderes o voluntades referidas. Así quedaban determinados o condicionados los efectos jurídicos a la ejecución de ciertos ritos, gestos o palabras, los que resultaban necesarios no para constancia o prueba de los actos jurídicos, sino para su existencia y consecuencias. Desaparecida luego, en buena medida, aquella influencia, las formas obedecerán, más que a un sentido tradicionalista, a los requerimientos de una inequívoca objetividad en la expresión de la voluntad.

(H) TENDENCIA A LA GENERALIZACION Y SISTEMATIZACION

Las normas jurídicas de los otros pueblos antiguos se nos han objetivado en textos legislativos casuísticos —porque se prevén “casos”, es decir, conductas, relaciones y situaciones particulares, concretas—, o formularios, o colecciones de fallos sin explícitos ni implícitos principios o pautas generales que es-

structuren un sistema coherente y autosuficiente del que pueda deducirse un criterio para una conducta, situación o relación nueva, es decir, no prevista.

En la ley de las XII tabas, en cambio, ya se advierte la formulación relativamente generalizada o abstracta de normas que parecen configurar un sistema —aunque en su mayor parte implícito— en el que se insertan aquellas reglas que se nos presentan aparentemente aisladas o inconexas.

Es que en Roma, a pesar de que sus juristas trabajaron apegados a la realidad, es decir, con concretez y en forma casuística, desde el comienzo se marca una propensión a la formación de un sistema pleno y generalizado —por lo menos en el nivel de la tipicidad * institucional— al que puedan referirse por vía jurisprudencial todos los casos posibles de darse concretamente en la realidad.

LAS MORES MAIORUM Y LA DISCIPLINA PONTIFICAL

La primera normativa del Derecho Romano fueron las *mores maiorum* * (costumbres de los antepasados), “modos de vivir” de los grupos gentilicios que concurren a la génesis de Roma.

Esos modos de vivir, ya cristalizados —es decir, ya institucionalizados, aunque no expresados conceptualmente— antes de aquella génesis, pasan a incrementarse con nuevas reglas propias de la integración de una comunidad más amplia, diversificada y compleja: la de la *civitas* *.

Pero esa *civitas* se define por la aparición de órganos que coordinan y resuelven conflictos entre aquellos grupos parentales: el *rex* y sus continuadores, los magistrados con *imperium*, en el ejercicio de la *iurisdictio*, y los pontífices, tal vez también con *iurisdictio*, y, sin duda, con una labor doctrinaria interpretadora de las *mores maiorum*, es decir, una *iurisprudencia*, aunque con un carácter de monopolio “oficial” que contrasta con la actividad privada, individual, que tendrán luego los que llamaremos juristas “laicos”.

Aquel complejo de antiguos modos o hábitos de conducta

de los grupos precívicos y los nuevos de la convivencia en la *civitas*, declarados en el oficio jurisdiccional y explicitados o enseñados en la actividad doctrinaria pontifical, constituyeron el *ius quiritium* (el derecho de los quirites [nombre con que los pueblos de los designaron a los antiguos romanos]).

- ¿Era ese *ius* de esencia consuetudinaria? Sin duda lo era en los momentos de integración de la *civitas*, pero cuando, como expresión de esa nueva realidad sociopolítica, aparece el colegio de los pontífices, el derecho arcaico deviene, fundamentalmente, en un derecho elaborado doctrinariamente, un derecho de juristas.
- Al efecto, el romano, ante un *ius* paulatinamente más rico y complejo de relaciones sociales empezará a buscar sus normas jurídicas no ya observando o recordando los hábitos de sus antepasados o contemporáneos, sino consultando al órgano específico de la nueva comunidad, en especial las reglas de actuación en los procesos de arbitraje en que el incipiente estado irá tomando una creciente intervención.
- Los pontífices, pues, serán los asesores de magistrados y particulares en cuanto a normas y ritos. El *ius* tendrá, pues, más que una explicitación a través de las costumbres, una consagración, una revelación a través del quehacer de juristas-sacerdotes. Y ese *ius*, si sólo se hubiera desarrollado, si sólo hubiera evolucionado consuetudinariamente, no habría acompañado la rápida evolución experimentada por la sociedad romana desde la integración de la *civitas*.
- Los pontífices, en cambio, si bien formalmente aparecían como intérpretes de una venerada tradición consuetudinaria, en realidad arrancaban de ella puntos de partida para, con versatilidad y audacia, articular innovadas instituciones, criterios y soluciones.

Resulta así, que sobre un presupuesto consuetudinario, la dinámica de desarrollo del *ius quiritium* lo caracteriza como un derecho de juristas, resultado del quehacer de los pontífices consistente en conservar las declaraciones o sentencias con valor de precedente, en explicitar los recitados y procedimientos rituales del accionar en justicia, y las fórmulas de actos jurídicos, en estar a disposición de los miembros de la comunidad para dar respuestas (*ad respondendum*) sobre el *ius*, para precaer (*ad cavendum*) sobre efectos y formas de futuros negocios jurídicos y para proporcionar reglas para accionar (*ad agendum*) en justicia.

LEGISLACION

En los primeros siglos de Roma, las relaciones privadas entre los grupos familiares, o, mejor dicho, entre los *paterfamilias*, sólo excepcionalmente fueron regladas por ley, aun después de estar ya constituido el *populus* en su expresión comicial.

Es que el sentimiento general era que esas relaciones debían darse en el accionar autónomo de los grupos familiares dentro de las costumbres de los antepasados (*mores maiorum*) y, sólo con el tiempo, llegaron a admitir que aquella autonomía y la venerada tradición pudieran ser interferidas, limitadas o abrogadas por pronunciamientos de los órganos de la nueva estructura político social, la *civitas* *.

Las pocas leyes existentes sobre derecho privado en esos primeros siglos de Roma se debieron a la necesidad de dar solución a problemas que si bien se referían a relaciones privadas, eran de trascendencia político social —la ley de las XII tablas, la *Cannuleia* * o la *Poetilia Papiria* *— o tenían el efecto de limitar ciertos aspectos del ejercicio del poder unitario irrestricto del *pater* en el viejo *ius*, poder que una nueva conciencia social consideraba conveniente encauzar.

LEY DE LAS XII TABLAS

Pero curiosamente, la primera formulación legislativa que conocemos, la ley de las XII tabas, fue la más completa y trascendente —“*fons omnis publici privatique iuris*” (“fuente de todo el derecho público y privado”) llegó a llamarla Tito Livio— y no fue nunca derogada, aunque la mayoría de sus disposiciones quedaron, con el tiempo, sin aplicación concreta, sobre todo por la labor jurisdiccional del pretor.

- * Se ha dicho la primera formulación, porque hoy en día los romanistas no creen en que las llamadas *leges regiae* (leyes reales) —conocidas también como *ius papirianum*— hayan sido propuestas por los *reges* para su aprobación por los comicios curiados. Se considera, en cambio, que se trata de posteriores normas sacrales emanadas de los pontífices y recopiladas por uno de ellos, Papirio.

El relato tradicional. — Los plebeyos planteaban la exigencia de un cuerpo de normas explícitas que dieran certidumbre y solución a algunos aspectos de su posición en la *civitas*. Ya en el 462 a.C. el tribuno Terentio Arsa había propuesto una comisión redactora de cinco miembros. Al cabo de ocho años de persistente acción plebeya el Senado aceptó que se eligieran por los comicios centuriados diez patricios para que constituyeran una suprema magistratura colegiada con *imperium* consular para que, además de gobernar, redactaran las leyes.

Previamente se envió una comisión a Atenas —y tal vez a la Magna Grecia— para conocer los cuerpos de leyes que, como el de Solón, habían surgido en las *poleis* helénicas.

Elegidos los decenviros en el 452 a.C., propusieron un conjunto de disposiciones que, aprobadas por las centurias, se grabaron en diez tablas de bronce o madera. Al año siguiente fueron designados otros diez magistrados, entre ellos reelegido Apio Claudio y elegidos por primera vez algunos plebeyos. El segundo decenvirato, luego de redactar otras leyes y de pretender perpetuarse en el gobierno fue desalojado por el pueblo indignado por el inicuo proceder de Apio Claudio, que cortó la vida de la joven Virginia. Restablecido el consulado, sus titulares hicieron aprobar en los comicios aquellas leyes que, grabadas en dos tablas, se expusieron junto a las otras diez anteriores. En el contexto de las dos últimas tablas habría quedado ratificada la no concesión del *connubium** entre patricios y plebeyos: esto sería dejado de lado, cinco años después, por la *lex Canuleia*. Las doce tablas habrían de desaparecer en ocasión de la toma de Roma por los galos en el año 390 a.C.

El problema de la autenticidad. — Anacronismos, contradicciones o incongruencias en el relato tradicional llevaron a que, con verdaderos alardes de hipercritica, Pais y Lambert, en nuestros días, negaran las circunstancias y el hecho en sí de la composición de la ley de las XII tablas: a lo sumo se trataría de una recopilación privada de preceptos doctrinarios desarrollados en el tiempo. Pero actualmente se está de acuerdo en: (A) la existencia de una magistratura decenviral a mediados del siglo V;

(B) la vigencia a partir de esa época de un ordenamiento jurídico común a patricios y plebeyos; (C) la autenticidad o, por lo menos, la antigüedad de casi todos los fragmentos atribuidos al famoso cuerpo legal. Se controvierte, en cambio, si efectivamente y en qué grado la plebe luchó por la publicación y carácter común del cuerpo de leyes, si tuvo lugar el viaje de estudios al mundo helénico, si los comicios ya actuaban en aquella época y si intervinieron, en tal caso, en la aprobación de la ley decenviral.

Contenido. — El texto destruido en el 390 a.C. habría sido, sin duda, reconstruido y, por lo demás, probablemente publicado con interpretación, notas y comentarios a principios del siglo II a.C. por Sexto Aelio Peto. Cicerón nos dirá que en las escuelas se lo recitaban de memoria los estudiantes; San Cipriano, que se lo exponía todavía, en el 254 d.C., en el foro cartaginés. Justiniano lo tuvo, sin duda, a la vista...

Pero luego desaparece toda indicación sobre él y todo ejemplar o documento directo. Lo que creemos conocer de las XII tablas lo hemos encontrado en citas, alusiones y comentarios dispersos en obras literarias, retóricas, gramaticales o jurisprudenciales. Con esos elementos aislados se ha tratado de determinar —con interrogantes y vacíos tal vez insolubles— el contenido y el orden de las disposiciones que habrían constituido el texto. La ubicación de esas disposiciones, eminentemente conjetural, se ha hecho sobre la base (A) de que cinco importantes fragmentos nos han llegado con la indicación de las tablas en que se incluían; (B) de la hipótesis de que Gayo ha seguido en sus seis libros de comentarios a la ley de las XII tablas el mismo orden en que las instituciones comentadas aparecían en el texto legal.

De acuerdo con la hipotética reconstrucción propuesta por Dirksen en 1824, la ley de las XII tablas habría contenido ese material que nos ha llegado a nosotros, distribuido de la manera que se consigna a continuación.

Tabla I — Citación y comparecencia en juicio.

Tabla II — *Legis actiones**. Obligación de testimoniar.

18

3044 1

Tabla III — Ejecución contra el deudor.

Tabla IV — Patria potestad*.

Tabla V — Disposiciones testamentarias; sucesión *ab intestato**; tutela* y curatela*.

Tabla VI — *Nexum**, *mancipatio**, *usucapio**, *trinoctium**; reivindicación*.

Tabla VII — Relaciones de vecindad*; servidumbres reales*.

Tabla VIII — Delitos y represión: compensación*.

Tabla IX — Prohibición de leyes que entrañen privilegios; apelación de las condenas capitales ante los comicios; delitos de homicidio, concusión y alta traición.

Tabla X — Disposiciones sobre funerales y sepulcros.

Tabla XI — Prohibición de *connubium** entre patricios y plebeyos.

Tabla XII — Casos en que es lícita la toma de prenda*; responsabilidad de los dueños por hurtos o daños cometidos por esclavos; indemnizaciones debidas por quien ha obtenido sin razón la posesión de una cosa y por quien ha consagrado al culto una cosa en litigio; el principio de que la ley posterior deroga la anterior.

La ley de las XII tablas se refería, pues, a todo el derecho civil romano —en su sentido de derecho propio de los *cives* romanos—: derechos privados, reglas procesales, derecho penal, garantías ciudadanas, derecho público y administrativo, etcétera.

No era por cierto un código que, como los modernos, tendía a cubrir con una completa sistematización de normas la totalidad del plexo institucional. En la ley decenviral sólo se inscriben algunos preceptos que aparecen como aisladas expresiones de todo un sistema latente o subyacente. Es decir, de toda una masa normativa consuetudinaria —*mores maiorum*— y doctrinaria —la interpretación pontifical— y de pronunciamientos de la *iurisdictio* del *rex* y los magistrados sucesores, la

ley de las XII tablas ha seleccionado algunas reglas o criterios, sea para destacarlos en forma precisa, sea para ampliarlos por analogía, sea para afirmar alguna innovación soslayadora o derogatoria.

* Así, los fragmentos que aluden a la emancipación* y al *trinoctium** no parecen haber ido acompañados por la previa descripción de las instituciones fundamentales de la patria potestad*, la *mancipatio**, el *mancipium**, el *usus**, la *manus**, etcétera. Es que todas estas viejas instituciones se daban por supuestas y lo que se había querido destacar eran nuevos procedimientos para soslayarlas o nuevas aplicaciones.

DERECHO PRECLASICO

LOS SISTEMAS ESTRATIFICADOS DEL DERECHO PRECLASICO

En el derecho preclásico las normas jurídicas aparecen encuadradas o referidas a distintas masas o sistemas según su fuente o su ámbito de aplicación. Sólo en el período clásico se irá tendiendo a una integración sustancial en una unidad superior, aunque persistirán hasta Justiniano ciertas distinciones formales o nominales.

I. El *ius civile*, concebido inicialmente como el desarrollo jurisprudencial de las *mores maiorum*, aparece como contrapuesto al *ius publicum* o *legitimum* emanado del *populus* estructurado en comicios. Con el tiempo, esa relación de contraposición pasó a ser de fuente a producto: la *lex publica* es una fuente más y sus normas son tan integradoras del *ius civile* como las resultantes de la *interpretatio* de pontífices o juristas laicos.

II. Ese *ius*, ampliado en sus fuentes, a su vez apareció contrapuesto o deslindado —por su aplicación exclusiva a los *cives*— a las instituciones resultantes de la *iurisdictio** del pretor peregrino que integraban el *ius gentium*. Elaborada sobre este último la doctrina resumida por Gayo en el fragmento* que se ha transcrito, se entendió que, siendo aquellas instituciones comunes a todos los pueblos, integraban también el *ius* propio de los *cives* romanos y estaban también sujetos a la labor doctrinaria de los juristas.

III. Se forma así una ampliación del *ius civile*, que tiende a contraponerse con el *ius honorarium* del pretor urbano, dando lugar a dos vertientes operantes dialécticamente hasta que, agotada la creatividad de la magistratura en tiempos del Edicto Perpetuo, la doctrina destacará la íntima síntesis de ambas, "pues el mismo *ius honorarium* es la viva voz del *ius civile*", según afirmó Marciano.

LA LABOR DOCTRINARIA DE LOS JURISPRUDENTES

El colegio pontifical fue dejando de ser órgano exclusivo de la interpretación del *ius* en la medida en que el conocimiento de éste fue siendo transferido al público, ya por la explicitación de la ley de las XII tablas, ya por la edición de los formularios procesales hecha en el 304 a.C. por Gneo Flavio, ya por las consultas que comenzó a evacuar públicamente Tiberio Coruncanio, prestigioso jurista y primer pontífice plebeyo.

Los miembros de la clase dirigente patricio-plebeya fueron reemplazando a los pontífices en el cultivo del derecho, en el que entendían servir a la comunidad y especialmente a la clientela política de sus familias y consolidar así sus expectativas en el *cursus honorum* *.

Esa actividad doctrinaria se canalizó especialmente a través (A) de las respuestas a consultas particulares, (B) del asesoramiento al magistrado, (C) del quehacer didáctico, y (D) de la redacción de trabajos.

- * (A) Las consultas podían versar sobre negocios y situaciones extrajudiciales o sobre el accionar judicial.
- * (B) Los jurisprudentes, cuando ellos mismos no eran magistrados, integraban el *consilium* de amigos con el que se aconsejaban los magistrados.
- * (C) A las audiencias en que los jurisprudentes evacuaban las consultas concurrían regularmente grupos de jóvenes, admitidos con la finalidad de entrar en contacto con la problemática allí elucidada y de solicitar posteriormente aclaraciones y sistematizaciones necesarias a su formación como futuros juristas.
- * (D) Pero no hubo en esos tiempos obras didácticas: se componían, sobre todo, de colecciones de *responsa* (respuestas) o de formularios necesarios para los negocios jurídicos, y sólo al final del período preclásico

se redactaron comentarios sistemáticos a la ley de las XII tablas y, en general, al *ius civile*.

PERIODOS DE LA JURISPRUDENCIA PRECLASICA

I. El primero abarca el subperíodo que se ha denominado "perfeccionamiento de la integración patricio-plebeya" (367-287 a.C.) y se caracteriza por el comienzo de la transferencia de la función jurisprudencial a las más relevantes figuras de la clase dirigente: Apio Claudio —tal vez inspirador de Gneo Flavio—, Escipión Nasica y Tiberio Coruncanio.

II. El segundo corresponde a los subperíodos de equilibrio y apogeo de la *civitas* y de vigencia de las tendencias oligárquico imperialistas (287-133 a.C.). Se destaca en este período Sexto Elio Peto, autor de *Tripertita*, obra integrada por un libro de la ley de las XII tablas, por otro con su interpretación y por un tercero que trata de las *legis actiones* *. Al final del período ya los juristas influyen decididamente en el *ius honorarium*.

III. En el tercer período —que corresponde a las épocas de crisis de la *res publica* y de las guerras civiles— comienza —con los "fundadores del *ius civile*", Junio Bruto, Mario Manilio y P. Mucio Scaevola, y con Q. Mucio Scaevola, Aquilo Galo, Servio Sulpicio Rufo y Alfenio Varo— el tratamiento científico del derecho con el aporte generalizador, clasificador, sistemático del pensamiento griego.

LEGISLACION

A pesar del trascendente papel de la actividad individual, privada, de los juristas en el desarrollo del *ius*, el estado irá adquiriendo paulatinamente una mayor presencia como imponente de normas a través de órganos específicos: el legislativo —magistrado y comicios— y el jurisdiccional —el pretor.

LEX

Dado el carácter contractual de la *lex rogata*, proveniente de la coincidencia de la voluntad del magistrado que propone

19 504 1

e interroga (*rogat*) y la del pueblo que acepta, se la ha definido como la "común *sponsio* * de la *res publica*".

En cambio, la *lex data* es la "dada" en la esfera de su *provincia* * por el magistrado, autorizado previa o implícitamente por los comicios.

Partes de la *lex rogata*. — Son la *praescriptio*, la *rogatio* y la *sanctio*.

La *praescriptio* (lo escrito al principio), como su nombre lo indica, encabeza la *lex* con el nombre del magistrado proponente, fecha y lugar de los comicios, con indicación de la primera unidad de voto escrutada y su primer ciudadano sufragante.

La *rogatio* era exactamente lo propuesto e interrogado por el magistrado: el contenido preceptivo, con las, si fuese el caso, sanciones contra la violación.

La *sanctio* era un com lejo de cláusulas formales que pretendía evitar, prever o solucionar eventuales conflictos de la *lex* con otras normas existentes o futuras del *ius*.

- * Las leyes se designaban con un adjetivo formado sobre el nombre del magistrado proponente y con una indicación del asunto tratado: *lex Auleia* * de connubio, *lex Aquilia* * de damno.

Clasificación de las leyes. — Según un criterio muy posterior de Ulpiano, podían dividirse, en función de lo que establecían para el caso de violación, en (A) perfectas, las que estatúan la nulidad de lo actuado en su transgresión; (B) menos que perfectas, las que no invalidaban lo cometido en contra de sus normas pero fijaban una multa a los autores — caso de la *lex Furia* * —; (C) imperfectas*, las que no declaraban nulo ni multable al actuar prohibido.

- * Estas últimas leyes — inconcebibles para nosotros — se originaron en los primeros tiempos cuando era fuerte la resistencia a admitir injerencias del estado en la órbita de acción tradicionalmente librada a la irrestricta autonomía de los *patresfamilias*. De todos modos, llegaron a tener no sólo un valor simplemente admonitorio, sino también relevancia jurídica cuando el ejercicio de la *iurisdictio* del pretor les fue quitando, con la *exceptio**, efectividad en las instancias procesales a los actos efectuados en transgresión.

PLEBISCITO

Es lo que aprueba el concilio de la plebe instado por el magistrado convocante. Como la *lex Hortensia* * lo equiparó a la *lex*, se comenzó a darle también esa calificación.

En razón del quehacer político social de los tribunos y de su permanencia en la ciudad — frente a las actividades militares de los cónsules —, el grueso de la legislación de derecho privado consistió en plebiscitos.

SENADOCONSULTO

En el período preclásico el senadoconsulto, como opinión o respuesta del Senado a la consulta de un magistrado, no era de un originario y directo valor preceptivo que se pudiera equiparar al de la *lex*, sino que se imponía como norma a través del *imperium* o *potestas* de los magistrados, que se plegaban a aquella opinión que representaba el sentir de la clase dirigente de la que ellos eran temporarios brazos ejecutores. Por lo demás, el pretor, en su manejo discrecional de las acciones procesales, reconoció siempre al senadoconsulto la misma relevancia que a la *lex* y al plebiscito.

LA LABOR JURISDICCIONAL

Cuando una nueva sociedad más articulada y compleja planteó problemas cada vez más difíciles de resolver a través de la ingeniosa interpretación de las *mores maiorum* realizada por los juristas y cuando la laicización del derecho dejó abiertas las vías de cambio para un *ius* hasta ese entonces vinculado al pensamiento mágico religioso, la intervención del estado, a través de la expresión comicial, produjo *leges publicae* que, como vimos, contrapuestas inicialmente al derecho deducido de las *mores maiorum*, acabaron por integrarse con él. Pero tal fuente normativa resultaba inconveniente e insuficiente: el *modus ope*.

randi llevaba a distraer a los *cives* de sus trabajos y la expresión mayoritaria de ellos no era necesariamente garantía de eficiencia en una disciplina cuyo carácter rigurosamente técnico reconocían los romanos. Precisamente porque no concebían entonces otra forma de *lex* que la votada en procesos comiciales, la producción estatal de normas fue relativamente escasa durante la *res publica*. Cuando el estado esté organizado sobre la base de un concentrado y unitario poder del *Princeps*, encabezando una creciente y compleja burocracia, entonces los juristas agrupados en el *consilium* imperial serán los inspiradores de una legislación impuesta, en forma tal que llegará a ser monopólica, por esa verdadera personificación del estado que será el *Princeps* o el *Dominus*.

En la *res publica*, en cambio, se desarrolló una original fuente normativa que permitió superar las limitaciones de la *interpretatio* jurisprudencial y los inconvenientes y costo social de la legislación comicial: el *imperium* del magistrado, que, desarrollando con imaginación las posibilidades de sus recursos procesales y extraprocesales, llegó, como afirma Papiniano, a "complementar y corregir al *ius civile* en razón de la pública utilidad"; que requería desechar antiguos criterios, adaptar o ampliar otros y promover la institucionalización de otros nuevos. Se desarrolló así el *ius honorarium* —por el *honor** del magistrado— o *praetorium* o *edictale* —por alusión al edicto como programa de política jurisdiccional del pretor.

1. A pesar del carácter originario y soberano de su *imperium*, en los primeros tiempos el magistrado debe de haber quedado limitado, en la organización de los procedimientos judiciales, tanto por las formalidades rituales de las *legis actiones**, como por la modalidad tradicional de impregnación mágico-religiosa del *ius*. Su papel, solemne pero meramente formal, debe de haber sido el de comprobar el cumplimiento de los requi-

sitos y ritos y el de darle carácter público al arbitraje en que consistía, fundamentalmente, el proceso romano arcaico.

II. El aludido desglose del *ius* con respecto a los complejos normativos mágico-religiosos y su consecuente disciplina técnico-racional deben, sin duda, haber abierto el camino a un más libre y, con el tiempo, audaz accionar de los magistrados encargados de la *iurisdictio**. Pero más trascendente fue el aporte y ejemplo que pudo prestar el pretor peregrino, encargado desde el 242 a.C. de entender en las instancias judiciales promovidas por peregrinos o en contra de ellos. Estos, cada vez más numerosos, como resultado de la expansión por la cuenca mediterránea, iban llevando a Roma negocios y hábitos jurídicos de diversos pueblos.

EL PRETOR PEREGRINO Y EL IUS GENTIUM

En virtud del principio de la personalidad* de las leyes, lo que Gayo llama, en general, *ius civile*, el propio y exclusivo de los *cives* de una comunidad —naturalmente los juristas romanos, cuando hablan de *ius civile*, aluden específicamente a la romana— no podía ser practicado ni invocado por quienes no fueron miembros de esa comunidad, aunque habitaran en el territorio de ésta. Así, los peregrinos en Roma eran juzgados, si había un tratado entre Roma y su comunidad de origen, por sus normas nacionales o las previstas en el tratado; pero si no lo había —y esto era lo más común— quedaban sometidos a la discrecionalidad y sentido equitativo del órgano jurisdiccional, el pretor único y, desde el 242 a.C., el peregrino.

Este último, asesorado por su *consilium* de juristas y con conocimiento y vivencias de instituciones extranjeras y prácticas del mundo de las transacciones pudo —libre, como era, de tener que limitarse a aplicar un derecho preexistente— crear para cada tipo de situación un criterio regulador en el que jugaba ampliamente la apreciación de la naturaleza de las cosas, de la real voluntad de las partes y de básicos principios de lealtad y eticidad de las relaciones.

Se originó así en un tribunal romano, con mentalidad romana y con instituciones y prácticas romanas y de otros pueblos, un nuevo conjunto normativo, caracterizado por su ámbito regulador de las relaciones entre peregrinos y entre peregrinos y ciudadanos romanos y teorizado posteriormente por los juristas como *ius gentium*.

Se encontraban allí instituciones antes exclusivas del *ius civile*, como la *stipulatio*, que se habían ido facilitando a los peregrinos, instituciones extrañas, como el *fenus nauticus* (préstamo marítimo) o el régimen de la *lex Rhodia* * de iactu (echazón), y, sobre todo, nuevas prácticas y modalidades del mundo de las transacciones comerciales bajo un común denominador de lealtad (*fides*) en los procederes, que con el nombre de *bona fides* * adquirirá, incluso en el tribunal del pretor urbano, el mismo carácter vinculatorio que los preceptos del *ius* y de las *leges*.

LA FORMULA Y EL EDICTO, PILARES DEL IUS HONORARIUM

En efecto, la conveniencia y funcionalidad de esas instituciones y criterios provocó su recepción por parte del pretor urbano, que los introdujo así en el sistema jurídico aplicable a los romanos.

- En el capítulo VIII, al historiar el desarrollo del procedimiento formulario, se describe cómo el pretor urbano comenzó a usar las formas procesales más libres que aplicaba el pretor peregrino, y cómo la redacción de la fórmula * le significó la manera versátil y fecunda de producir transformaciones trascendentes.
- También se explica allí cómo el manejo discrecional —propio del *imperium* *— de sus recursos procesales * y extraprocesales * puede llevar al pretor a negar o condicionar un proceso cuando la pretensión jurídica se basa en un criterio ya obsoleto o chocante del viejo *ius civile*, y cómo, por el contrario, puede otorgar un proceso en cuya fórmula * articula la manera de proteger una relación o situación hasta ese momento no contemplada en el ordenamiento vigente.

Puede parecer que esa discrecionalidad originaba una falta de seguridad jurídica, pero el pretor no hacía otra cosa que ir paulatinamente institucionalizando nuevas soluciones y valoraciones expresadas por los juristas. Y esa institucionalización se hacía pública —como un compromiso ante la comunidad— en el edicto *, que resulta así, como se advierte en el transcrita fragmento * de Gayo, una de las partes constitutivas —nosotros hablaríamos de fuentes— del Derecho Romano.

- Como se verá en el capítulo VIII, el edicto aparece como un repertorio de fórmulas en el que se impondrán las posibles controversias cuyo sometimiento a un *iudicium* significa la dación de una *actio* por parte del magistrado.
- En efecto, en la primera etapa del procedimiento ordinario romano, oídas las partes, el magistrado encuadra o plantea los términos de la *litis* de acuerdo con normas del *ius* preexistente, o con criterios establecidos en su edicto o que adopta en el momento, aconsejado por su *consilium* de juristas y movido por razones de equidad o conveniencia social (*publica utilitas*). En la concreta fórmula resultante se ordena al juez que expresamente se designa en ella, que, comprobados o no determinados supuestos, sentencie en uno u otro sentido de dos que se dan en alternativa.
- El juez no tiene que buscar en el ordenamiento jurídico cuál es la norma aplicable al caso; ella está implícitamente desarrollada en la concreta fórmula cuya estructura en abstracto está prevista —salvo el caso de un *decretum repentinum* *— en el edicto.

EL DERECHO ROMANO COMO UN SISTEMA DE ACCIONES

Por ello, el Derecho Romano, sobre todo en su período clásico, aparece estructurado más como un sistema de acciones a concederse en la forma de confección de una fórmula, que como un conjunto normativo del que se derivan explícitamente derechos subjetivos.

I. Hoy en día, si de una establecida norma —derecho objetivo— nace para una persona una facultad de exigir de otras una específica conducta, esa facultad es un derecho subjetivo porque lleva insita la posibilidad de reclamar en justicia —ac-

ción— a aquella conducta o, eventualmente, un correlativo sucedáneo en forma de indemnización.

Es decir, el esquema sería: derecho objetivo → derecho subjetivo → acción.

II. Pero la *iurisdictio**, en el período clásico del Derecho Romano, nos presenta un esquema distinto. El magistrado podía conceder acción a quien no tenía, hasta ese momento, un derecho subjetivo basado en una norma del derecho objetivo. Al ordenar el magistrado, en la fórmula, que el juez, una vez comprobados ciertos supuestos, sentencie en modo tal que una relación o situación adquiera una relevancia jurídica hasta ese momento no otorgada institucionalmente, ¿no está consagrando un nuevo derecho subjetivo? Y si no hay duda de que esa relación o situación seguirá siendo contemplada en la praxis jurisdiccional, ¿no significa ello que se ha enriquecido el ordenamiento jurídico con un nuevo criterio normativo, no formulado explícitamente pero contenido implícitamente en el otorgamiento de aquella fórmula?

Por lo tanto la concesión de acciones lleva a efectivizar o a consagrar derechos subjetivos que suponen un ampliado ordenamiento jurídico. Esquemáticamente: acción → derecho subjetivo — derecho objetivo.

DERECHO CLASICO

CARACTERES

UNIVERSALISMO

La incorporación de criterios del *ius gentium* y la atenuación de los antiguos particularismos lleva a un derecho en función del hombre libre del mundo cultural greco-romano y no de una comunidad nacional.

DECRECIENTE FORMALISMO

Aunque subsistían las formalidades del viejo *ius*, la praxis jurisdiccional había superado o mitigado ciertas exigencias, al

dar relevancia a algunos negocios jurídicos incompletos o deficitarios formalmente —senadoconsulto Neroniano*—, o al otorgar una protección supletoria a situaciones en las que no se habían cumplido las formalidades —la *bonorum possessio** concedida de acuerdo con un *testamentum praetorium**.

DECRECIENTE RIGIDEZ

Amplios principios o criterios como el de la *aequitas**, *bona fides**, *publica utilitas**, elástica y funcionalmente aplicados llevaron a ir atenuando o suprimiendo el rigor del antiguo *ius* y a permitir así una más flexible y justa aplicación del derecho.

PAULATINA ABSTRACCION

Por influencia del pensamiento filosófico los juristas superaron su tendencia casuística y su apego a la realidad concreta, y fueron capaces de llegar a formulaciones generalizantes y a la tipificación de instituciones.

CRECIENTE USO DEL DOCUMENTO ESCRITO

En los primeros tiempos, las pocas veces que se empleó la escritura en los negocios jurídicos sólo servía —salvo en los contratos *litteris*— como una evidencia más de que las formalidades inherentes a aquéllos habían tenido lugar. Pero por influencia greco-oriental y por las complejidades de los contratos consensuales se incrementó la práctica de la escritura y su valor probatorio, en muchos casos inatacable.

LA LABOR DE LOS JURISTAS CLASICOS

Se caracterizó por (A) su especial aplicación a estructurar en un ordenamiento coherente los antiguos sistemas estratificados del período preclásico y las nuevas tendencias —*ius novum*— que se consagraban en la *cognitio** *extra ordinem*; (B) por la rigurosa lógica y técnica con que se manipularon las tendencias innovadoras de la normativa imperial y las in-

21 504 1